

Há redes formadas para realização de atividades construtivas e positivas do ponto de vista social – como os arranjos produtivos, as cadeias organizadas de suprimentos, as redes de pesquisa científica. No Currículo Lattes, ao lado da tela inicial de abertura, há um *link* que remete à rede de colaboradores, conforme levantado pelo CNPq, dos pesquisadores. Trata-se do reconhecimento oficial da importância da pesquisa científica em rede.

Há, todavia, redes criadas para atividades destrutivas e/ou para o cometimento de crimes – como as organizações terroristas e de traficantes. São formadas por “indivíduos que se engajam na atividade criminosa através de alianças voláteis”. Quando um de seus componentes é identificado, “a rede imediatamente se desfaz e reagrupa-se ao redor de outro líder”.¹

Seja qual for sua intenção/missão, as redes compartilham essa característica de volatilidade, o que faz delas **organizações policêntricas**.

Há organizações feitas de redes internas de grupos autogeridos. As grandes organizações, com elevado grau de dispersão geográfica, contam com arranjos complexos de redes internas e com outras organizações.

3.5 Max Weber e a burocracia

Com papel tão importante na sociedade, as organizações atraíram a atenção de inúmeros estudiosos. O principal foi Max Weber. De acordo com ele, qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma **burocracia**. Para Weber, a burocracia viabilizou o desenvolvimento do capitalismo, que, diante do crescimento e da maior complexidade das instituições, passou a exigir modelos mais bem definidos de organizações.

Weber nasceu em 1864, na Prússia. Em 1920, faleceu após contrair a gripe que assolou a Europa na época, matando mais gente do que a Primeira Guerra. *Economia e sociedade* é seu livro mais famoso e abrangente. A síntese de suas proposições neste capítulo foi obtida na

tradução para o espanhol de sua edição alemã.² Essa obra trata da **burocracia** em diversas passagens.

Apesar de a burocracia ter adquirido um sentido pejorativo nos dias atuais, apontando para distanciamento, frieza e ineficiência organizacional, este não foi o sentido que Weber trabalhou em sua obra. A conotação negativa tem relação com as disfunções da burocracia, o que atualmente é chamado burocratismo, ou seja, dizem respeito a um estado patológico,³ mas não a seu funcionamento regular, tido como mais eficiente por Weber em comparação com os modos tradicionais e patriarcais de dominação.

Outro ponto digno de menção é que atualmente se fala em burocracia com associação à Administração Pública, mas Weber não restringiu sua análise à burocracia estatal, tendo focado a burocracia estabelecida em variadas organizações.

Burocracias são todas as **organizações formais** modernas, públicas e privadas.

Há uma razão extremamente importante para se entender o que é a burocracia: a sociedade organizacional é, também, uma **sociedade burocratizada**. Todas as organizações a que as pessoas estão ligadas de alguma forma são burocracias, regidas por regulamentos que criam direitos e obrigações. Entender isso também serve para adotar perspectiva reflexiva da burocracia e buscar, portanto, aprimorá-la.

3.5.1 Conceitos fundamentais

Entre os conceitos fundamentais de Weber que permitem entender as organizações e a burocracia estão a **dominação** e a **racionalidade**.

- **Dominação** é a “probabilidade de um mandato (ordem ou comando), de determinado conteúdo, entre pessoas, ser obedecido. Uma associação se chama **associação de dominação** quando seus membros estão submetidos a relações de dominação em virtude da ordem vigente”.⁴
- Existem três **tipos puros de dominação legítima**, segundo Weber. A de caráter **racional**, a primeira em sua análise, “repousa sobre a crença

na legalidade de ordenações estatuídas e dos direitos de mando dos que foram chamados por essas ordenações a exercer a autoridade (autoridade legal). No caso da autoridade legal, as pessoas seguem **ordenações impessoais** e objetivas, legalmente estatuídas, e as pessoas por elas designadas, por causa da legalidade formal de suas disposições dentro do círculo de sua competência”.⁵

- A autoridade impessoal da lei contrasta com a **autoridade tradicional**, em que se obedece à pessoa que representa as tradições, e com a **autoridade carismática**, em que se obedece à pessoa que representa revelação, heroísmo ou exemplo.

A formação da burocracia significa, portanto, avanço significativo em relação às outras estruturas de poder ou tipos de domínio (*Herrschaft*)⁶ existentes até então. Na abordagem weberiana, o domínio legítimo se subdivide em três formas: carismático, tradicional e legal-burocrático:

- o **domínio carismático** é legitimado com base na suposição de que o líder detém poderes e qualidades excepcionais, o que justifica a presença de discípulos no aparelho administrativo. Estes são indivíduos escolhidos pelo chefe por cultivarem devoção afetiva pela pessoa do senhor, sendo o reconhecimento dessas qualidades visto quase como dever, numa relação pessoal e autoritária. Para atuação dessa dominação nos quadros administrativos é necessário que haja ordens proclamadas de forma pessoal e geralmente não dialogada;
- o **domínio tradicional** é constituído pela crença de regras e poderes antigos, considerados imutáveis. O tipo do que ordena é o senhor e os que obedecem são vistos como súditos. O quadro administrativo é formado por servidores. Trata-se de uma área em que imperam o arbítrio e a graça, em que o patriarca age de acordo com simpatias e antipatias, isto é, de forma pessoal, sendo a administração preenchida por dependentes pessoais, amigos e pessoas ligadas por fidelidade ao senhor;
- o **domínio racional-legal** se baseia na regra estatuída, que submete

também quem ordena. Os estatutos contemplam regras de competência determinadas por utilidade objetiva e especialização nas atividades. A base de funcionamento técnico é alicerçada na hierarquia, a ser realizada de forma impessoal, segundo regras racionais, afastando-se do arbítrio. Admite-se, no máximo, a conveniência objetiva com base em direito de representação regulamentado.

As pessoas que integram as organizações modernas aceitam a autoridade legal como forma racional e legítima de convivência. Também aceitam que algumas pessoas representem a autoridade da lei: guardas de trânsito, juízes, prefeitos e gerentes.

A autoridade é contrapartida da responsabilidade que têm essas pessoas de zelar pelo cumprimento da lei e pelos interesses da comunidade. A obediência é devida às leis, formalmente definidas, e às pessoas que as representam, que agem dentro de uma jurisdição. Qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia. Essa é a interpretação ideal da **burocracia**, que Weber consolidou no seu **tipo ideal**.

3.5.2 Tipo ideal de burocracia

As organizações formais ou burocráticas apresentam três características principais, que as distinguem dos grupos informais ou primários: formalidade, impessoalidade e profissionalismo, sintetizadas na [Figura 3.5](#).

Essas três características formam o chamado **tipo ideal de burocracia**, um *constructo* de Weber. O tipo ideal é um modelo abstrato que procura retratar os elementos que constituem qualquer organização formal do mundo real. Não é uma proposição prescritiva. O que se segue é uma interpretação das ideias de Weber. Ele não usou exatamente essa classificação.

3.5.2.1 Formalidade e respeito às leis

- **Legalidade** ou formalidade significa que as organizações burocráticas são constituídas com base em normas e regulamentos explícitos – como as leis – que estipulam os direitos e deveres dos participantes. Tanto os “súditos” quanto os “senhores” estão sujeitos à lei. As normas são **racionais** – aceitas porque as pessoas acreditam que são formas legítimas de ordenar a vida da coletividade.

As leis criam **figuras de autoridade**, que têm o direito de emitir ordens. Violar as leis é comportamento passível de punição, que também está prevista e regulamentada. As figuras de autoridade são responsáveis pelo cumprimento das leis, às quais também estão sujeitas. Weber usa palavras como **soberano**, **magistrado** (no sentido dos romanos) e **autoridade** para indicar essas figuras.

Na burocracia, o comportamento sempre é regulamentado de forma explícita e vale para todos. Essa é uma das grandes vantagens da burocracia: **todos são iguais perante a lei**.

3.5.2.2 Obediência às ordens de forma impessoal

- **Impessoalidade** significa que, numa burocracia, nenhuma pessoa é empregada ou vassalo de outra. Nas palavras de Weber, “[...] os membros da associação, ao obedecer ao soberano, não o fazem por atenção a sua pessoa, mas obedecem à ordem impessoal e somente estão obrigados à obediência dentro da competência (ou jurisdição) limitada, racional e objetiva, a ele (soberano ou magistrado) outorgada por essa ordem”.⁷

FORMALIDADE

• O alicerce da burocracia é a legislação racional.

IMPESSOALIDADE

• A obediência é devida aos cargos, não às pessoas.

PROFISSIONALISMO

• Burocracias são sistemas de trabalho remunerado.

Figura 3.5 Tipo ideal de Weber

A legalidade e a impessoalidade fazem a burocracia permanecer a despeito das pessoas, de tal sorte que, mesmo em caso de revolução ou ocupação por um inimigo, a máquina burocrática continua funcionando normalmente, da mesma forma como o fazia no governo legal anterior.

Há casos em que o retorno da legalidade nem sempre implica o desmantelamento do aparato burocrático criado no regime anterior.

Existem inúmeros exemplos que comprovam esse princípio. Um deles é a sobrevivência do Senado romano sob a ocupação “bárbara”. Outro exemplo é a permanência de instituições criadas pelos nazistas mantidas depois da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo a parcela da estrutura administrativa brasileira, da descentralização feita, herdada da ditadura militar brasileira, conforme criada pelo Decreto-Lei 200/67.

3.5.2.3 Profissionalismo

■ **Profissionalismo** significa que os cargos da burocracia oferecem a seus ocupantes carreira profissional e meios de vida, além de formação. O integrante de uma burocracia é um funcionário que faz do cargo meio de vida, recebendo remuneração regular em troca de seus serviços. A escolha para ocupar o cargo deve-se a suas qualificações, comprovadas em exames de seleção, e aprimoradas por meio de treinamento especializado. A participação nas burocracias tem **caráter ocupacional**.⁸

As burocracias, especialmente as mais antigas, têm sistemas de formação para fornecer a seus profissionais o treinamento especializado. Diplomacia, forças armadas, polícia, instituições religiosas e administração pública são exemplos de burocracias que têm seus próprios sistemas de formação e desenvolvimento de competências.

Atualmente, conforme será visto, no Brasil, são as escolas de governo

previstas no art. 39, § 2º, da Constituição responsáveis pela formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. As escolas de governo fornecem aos servidores o treinamento especializado para que haja maior profissionalismo na burocracia.

3.5.3 Vantagens da burocracia

Nas palavras de Weber, a burocracia oferece

[...] precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiança, consequentemente, calculabilidade, para o soberano e os interessados [...] e suscetibilidade técnica de perfeição para alcançar os resultados ótimos. [...] Toda nossa vida cotidiana está tecida dentro desse marco. Já que a administração burocrática em geral é a mais racional do ponto de vista técnico-formal, é hoje simplesmente inseparável das necessidades da administração de massas. É preciso escolher: burocracia ou diletantismo. Sem burocracia, estaríamos reduzidos a uma civilização de camponeses. [...] A administração burocrática significa dominação graças ao saber; que é seu caráter racional fundamental e específico. [...] A dominação burocrática tem limitações para quem não é profissional: os burocratas quase sempre impõem sua vontade aos ministros não profissionais.⁹

3.6 Disfunções da burocracia

O trabalho de Weber sobre o tipo ideal provocou muita reflexão sobre as organizações reais. São elas realmente como Weber as retratou em seu tipo ideal? Será a burocracia tão cheia de vantagens como ele a fez parecer? Não será o tipo ideal uma abstração por demais idealizada?

Questões como essas foram levantadas por muitos autores, que se propuseram a analisar criticamente a realidade retratada por Weber. Estão nesse caso Charles Perrow, William Roth e Robert K. Merton, que catalogaram algumas **disfunções da burocracia**. Antes de tratar desses autores, consideremos o patrimonialismo analisado por Weber.

3.6.1 Patrimonialismo

O próprio Weber, analisando as formas de dominação, incluiu o **patrimonialismo** entre elas. Ele não chama o patrimonialismo de disfunção, mas está claro que é uma forma de dominação distinta do tipo ideal de burocracia.

Sempre em suas palavras:

Chama-se **dominação patrimonial** a toda dominação predominantemente orientada pela tradição, mas exercida em virtude de um direito próprio [...]. Deve-se entender por **dominação estamental** aquela forma de dominação patrimonial em que determinados poderes de mando e suas probabilidades econômicas correspondentes estão apropriadas pelo quadro administrativo. A apropriação, como em todos os casos semelhantes, pode ser: de uma associação ou categoria de pessoas que compartilham determinadas características, ou de um indivíduo.¹⁰

Patrimonialismo, no contexto do Brasil, é conceito associado à apropriação da Administração Pública por um estamento ou classe de “donos do poder”, numa fase **pré-burocrática** da história.

É o período que vai praticamente da Colônia até a década de 1930: aristocratas que derivam sua renda do patrimônio do Estado, ruralistas e políticos que dominam a Administração Pública e funcionários públicos admitidos por nomeação. No patrimonialismo brasileiro, a Administração Pública reproduz o modelo da monarquia portuguesa. O Estado tem como função garantir emprego para os parentes e agregados do poder; não há distinção entre público e privado; a democracia é rudimentar.

No final desse período, emerge um embrião de administração burocrática, com a qual se tenta corrigir os males do **patrimonialismo patriarcal**. Este não era uma disfunção da burocracia, porque não havia burocracia no sentido de tipo ideal. Era simplesmente um modelo predatório de governo colonialista.

3.6.2 Disfunções segundo Perrow¹¹

Charles Perrow acredita que o tipo ideal de Weber nunca é alcançado, porque as organizações são essencialmente sistemas sociais, feitos de pessoas. As pessoas não existem apenas para as organizações. Elas têm interesses independentes das organizações em que vivem ou trabalham e levam para dentro delas toda sua vida externa e suas imperfeições. Portanto, dentro das organizações coexistem a vida profissional do funcionário e seus interesses pessoais. Os funcionários não são seres exclusivamente burocráticos, e as organizações refletem as imperfeições dos seres humanos.

Além disso, a organização burocrática que Weber idealizou parece servir melhor para lidar com tarefas estáveis e rotinizadas, nas quais se baseia a eficiência. Portanto, o tipo ideal não retrata as organizações dinâmicas, para as quais a mudança é constante. De fato, o modelo weberiano parece retratar com mais propriedade as organizações mecanicistas, pouco dinâmicas, orientadas basicamente para as atividades padronizadas e repetitivas. Quando há muita mudança, cresce a dificuldade em se alcançar eficiência em estruturas burocráticas rígidas.

Além de questionar o tipo ideal de Weber, Perrow critica as próprias organizações formais, apontando as disfunções que o cientista alemão deixou de considerar em seu modelo. Perrow aponta quatro problemas que as organizações formais apresentam: particularismos, satisfação de interesses pessoais, excesso de regras e hierarquia. As duas primeiras são variantes do patrimonialismo.

3.6.2.1 Particularismos

Particularismo, segundo Perrow, é o que acontece quando as pessoas levam para dentro das organizações os interesses dos grupos de que participam fora dela. Muitas pessoas estão voluntária ou involuntariamente afiliadas a grupos externos, ou fazem parte de grupos sociais.

Amigos que se diplomaram na mesma escola ou no mesmo período,

clubes de serviço, grupos étnicos, pessoas que vieram da mesma região ou cidade, pessoas afiliadas ao mesmo partido político ou que compartilham a mesma ideologia política, ou grupos de interesses econômicos. Quando uma pessoa tem algum vínculo com um agrupamento qualquer, dessa ou de outra espécie, fora da organização, pode levá-lo para dentro dela.

Perrow aponta vários casos de particularismo, desde as “panelinhas” (grupos fechados) de pessoas formadas por uma mesma escola até a situação em que o funcionário contrata os serviços de uma empresa não porque sejam melhores que os da concorrência, mas porque o proprietário e ele frequentam a mesma igreja.

É o que hoje se chama **patrimonialismo burocrático** ou **burocracia patrimonialista** no Brasil. Essa ideia implica a influência de corporações de funcionários, sindicatos de trabalhadores de empresas privadas, grupos de agentes políticos e *lobbies* empresariais que forcem o governo a decidir muito mais em função de seus interesses do que dos da coletividade.

3.6.2.2. Satisfação de interesses pessoais

Satisfazer interesses pessoais consiste em usar a organização para fins pessoais do funcionário e não de um grupo, que é a disfunção anterior. No tipo ideal de Weber, o funcionário é recrutado, selecionado e treinado de acordo com suas qualificações e com as exigências de seu cargo.

A organização cumpre seus objetivos porque o funcionário realiza tarefas em estrita obediência a deveres oficialmente definidos. Na vida prática, muitas vezes o funcionário usa a organização para o atendimento de seus interesses pessoais e dificilmente age com a neutralidade prevista por Weber.

O processo de cuidar dos interesses pessoais está na raiz da corrupção e do nepotismo. Perrow cita ainda como exemplos dessa disfunção as trocas de favores com pessoas de dentro ou de fora da organização, o uso do horário de trabalho para tarefas pessoais e a utilização de recursos da organização para finalidades pessoais.

3.6.2.3 Excesso de regras

As organizações formais controlam o comportamento das pessoas por meio de regras. Regras são necessárias para a uniformização da conduta e para garantir igualdade de tratamento. Por isso, são sinônimo de justiça, especialmente no caso da aplicação dos meios de coerção previstos no **monopólio da violência** pelo Estado.

Frequentemente, porém, as organizações formais exageram na tentativa de controlar tudo o que for possível no comportamento humano, multiplicando os procedimentos, as exigências, os formulários, as etapas dos processos. Procurando prever tudo e tudo controlar, as organizações formais criam regras em excesso e funcionários em excesso para fiscalizar o cumprimento dessas regras.

Quando isso acontece, a burocracia torna-se sinônimo de complicações e muitas vezes permite, como se diz no senso comum, que funcionários desonestos criem dificuldades para vender facilidades.

3.6.2.4 Hierarquia

A hierarquia, segundo Perrow, é a negação da autonomia, liberdade, espontaneidade, criatividade, dignidade e independência. A hierarquia faz as pessoas procurarem orientação ou aprovação em quem se encontra em posição superior, a fim de não errar, promovendo por isso a rigidez e a timidez.

As pessoas ficam com medo de transmitir más notícias ou sugestões de aprimoramento para cima, porque isso pode significar que o chefe deveria ter pensado nas inovações mas não o fez. Subir na hierarquia pode, por isso, depender muito mais de habilidade política do que de talento.

Assim, e Perrow não está sozinho nessa crença, a hierarquia, paradoxalmente, muitas vezes atrai as pessoas sem talento, e que são capazes meramente de cumprir as regras e agir de acordo com aqueles que já se encontram nela, ou inibe as pessoas com talento. As organizações tornam-se então resistentes à mudança, pois as transformações ameaçam o

comodismo dos que estão no poder.

O **hierarquismo** é ainda mais disfuncional. O hierarquismo consiste na valorização excessiva da hierarquia e de suas formalidades, que passam a ser finalidades em si mesmas. A organização gasta muito tempo e energia com solenidades, cuidados com suas próprias instalações, privilégios e símbolos de prestígio de seus hierarcas, que se protegem de seus subordinados por meio de mecanismos coercitivos.

3.6.3 Disfunções segundo Roth¹²

Analizando a expansão das empresas industriais no início deste século, William Roth propôs-se a comentar os males do crescimento das organizações utilizando o esquema conceitual de Weber.

Roth reitera que as burocracias hierarquizadas reduzem a incerteza do comportamento dos empregados. No entanto, o crescimento das organizações acentua as desvantagens da burocracia, dificultando o processo de tomar decisões, por causa de cinco obstáculos principais: mecanicismo, individualismo, interrupção do fluxo de informações, desestímulo à inovação e indefinição de responsabilidade. Apesar de focalizar as empresas industriais do início do século, as críticas de Roth parecem continuar válidas para as organizações atuais.

3.6.3.1 Mecanicismo

O profissionalismo das organizações formais exige que as pessoas desempenhem papéis limitados, com responsabilidades limitadas e autonomia reduzida. Cada pessoa ocupa um cargo, que tem competências bem definidas. Frequentemente, as pessoas ocupam cargos que nada têm que ver com suas aptidões e interesses. As organizações burocráticas tornam-se contingentes de pessoas cujos talentos são subaproveitados.

3.6.3.2 Individualismo

A organização burocrática oferece muitas vantagens para pessoas alçadas às posições de chefia, como símbolos diferenciadores e vantagens materiais. Consequentemente, a burocracia incentiva o conflito entre as pessoas que desejam essas posições por causa de suas vantagens e realça a vaidade de seus ocupantes, prejudicando a qualidade da administração.

3.6.3.3 Desestímulo à inovação

Roth tem a respeito da hierarquia a mesma opinião de Perrow: pessoas que alcançam poder são perigosas e nunca se sabe como reagem. Aqueles que se encontram nos escalões intermediários não têm interesse em que os subordinados revelem talentos para a administração superior, porque isso também revela sua mediocridade. Portanto, o melhor a fazer numa hierarquia é manter-se quieto.

3.6.4 Disfunções segundo Merton¹³

Robert K. Merton, cientista social americano, fez inúmeras contribuições de grande alcance para o estudo das organizações e da administração. Merton também é conhecido por ter criticado o modelo weberiano, que, em sua opinião, negligencia o peso do fator humano.

Segundo Merton, as organizações não são racionais como Weber as retratou e apresentam disfunções ou anomalias nas características do tipo ideal. Para Merton, as principais disfunções são as seguintes:

- valorização excessiva dos regulamentos;
- excesso de formalidade;
- resistência a mudanças;
- despersonalização das relações humanas;
- hierarquização do processo decisório;
- exibição de sinais de autoridade;

- dificuldades no atendimento dos clientes.

3.7 Tipologias alternativas

Depois de Weber e dos críticos das disfunções, a pesquisa sobre as organizações continuou explorando as variações do tipo ideal. Esse caminho da pesquisa produziu a identificação de um modelo alternativo do tipo ideal weberiano, que com ele faz contraste.

Esse modelo alternativo retrata organizações cujo funcionamento depende mais das pessoas do que das regras impessoais da burocracia. É o **modelo orgânico** de organização – em contraste com o **modelo mecanicista** da burocracia –, associado ao conceito de **pós-modernismo na administração**, conforme vimos no capítulo anterior.

O modelo orgânico forma com o mecanicista uma “régua” ([Figura 3.6](#)), que possibilita avaliar o grau de burocratização das organizações.

3.7.1 Tipo mecanicista¹⁴

O **tipo mecanicista** (ou mecanístico, *mechanistic*) de organização é adequado a condições ambientais relativamente estáveis. As tarefas são especializadas e precisas. A hierarquia de controle é bem definida. A responsabilidade pela coordenação, assim como a visão de conjunto, pertence exclusivamente à alta administração. A comunicação vertical é enfatizada. Organizações desse tipo valorizam a lealdade e a obediência aos superiores.

O tipo mecanicista corresponde a duas situações do mundo real das organizações.

1. O primeiro é a burocracia legal-racional de Weber.
2. O segundo é a **organização-máquina**, ou máquina organizacional, representada pela linha de montagem. O desfile militar, as lojas de *fast food* e os *call centers* também funcionam como máquinas. Adiante veremos algumas ideias sobre as máquinas.

Nas máquinas, as pessoas fazem trabalho repetitivo, sem autonomia ou espaço para improvisação. Ninguém tem individualidade – a organização-máquina é impessoal e rígida –, ninguém é importante e nada pode fugir do previsto. Isso é possível com hierarquia centralizada, obediência a normas rigidamente definidas e trabalho padronizado, no estilo taylorista.

Na organização máquina:

- A administração enfatiza critérios de desempenho tais como eficiência, previsibilidade, segurança e aversão ao risco.
- Regras, regulamentos e procedimentos são bem definidos e estão escritos. A organização procura prever todas as possibilidades de comportamento e submetê-las a normas.
- As pessoas desempenham tarefas de escopo reduzido, ocupando cargos com responsabilidades específicas e bem definidas.
- A autoridade é centralizada e dá poder aos chefes, especialmente para produzir obediência. A fonte da autoridade é a posição da pessoa na estrutura organizacional.
- Os processos de gestão de pessoas são formalizados. A seleção faz-se por meios que colocam todos os interessados em igualdade de condições.

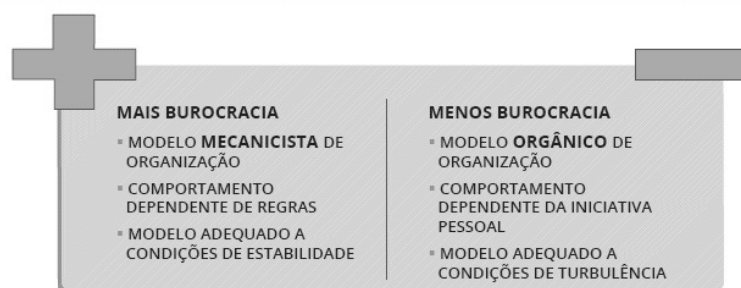


Figura 3.6 “Régua” da burocracia

3.7.2 Tipo orgânico

O **tipo orgânico** (ou organísmico, *organismic*) de organização é adaptado

a condições instáveis, a ambientes com os quais a organização não tem familiaridade. Ambientes assim oferecem problemas complexos que não podem ser resolvidos por pessoas com especialidades tradicionais. Por isso, nos sistemas orgânicos, há contínua redefinição de tarefas. Ninguém é especialista em nada, ou todos são especialistas em tudo.

A natureza cooperativa do conhecimento é enfatizada, não a especialização. Preferem-se a interação e a comunicação de natureza informativa (em lugar de ordens), o que cria um alto nível de comprometimento com as metas da organização. Os organogramas são de pouca utilidade para descrever as tarefas das organizações do tipo orgânico. Muitas vezes, elas não têm organogramas.

3.7.3 Modelo situacional de organização

Nenhuma organização é exclusivamente mecanicista ou orgânica. Uma força militar é mecanicista durante um desfile, e orgânica em combate. O departamento de produção de uma fábrica, assim como o de contabilidade, é mecanicista – o pessoal de pesquisa e desenvolvimento trabalha dentro de um padrão orgânico. O governo é uma grande máquina, mas suas universidades e institutos de pesquisa funcionam como organismos vivos e pensantes.

3.8 Representações complexas das organizações

O tipo ideal de Weber não dá conta de representar todos os tipos de organização, mas a polarização entre o modelo orgânico e o mecanicista também não. Assim, novos autores que entraram no campo do estudo das organizações ampliaram os modelos para interpretá-las.

Diversos tipos ideais foram criados e explicados de maneira sucinta, sem a profundidade analítica de Weber. Entre os principais autores que seguiram essa linha estão Henry Mintzberg, Charles Handy e Gareth Morgan. Numa outra linha estão os autores que interpretaram as organizações como **sistemas de aprendizagem**. O principal é Peter Senge.

4.1 Estado

A palavra Estado advém do latim *status* (estar firme) e designa uma situação permanente de convivência ligada à sociedade política.¹ É citada pela primeira vez na obra *O Príncipe*, de Maquiavel.

É bastante controvertida, no entanto, a origem do Estado, havendo até aqueles que procuram fixar uma data precisa para seu nascimento, a partir da assinatura do tratado de paz de Westfália, em 1648. Este compreende, na realidade, um conjunto de tratados celebrados entre países europeus, encerrando um longo período de guerras, o que deu início ao reconhecimento da noção de *Estado-nação soberano*.

Tal postura documenta, no máximo, a estruturação do Estado moderno, a partir do enfoque de unidade territorial dotada de poder soberano; contudo, existem outras correntes de pensamento que entendem que o surgimento do Estado deriva muito mais de uma situação variada no espaço e no tempo, afastando-se, portanto, da ideia de que haja *data certa* para o surgimento do Estado, como se fosse um ponto fixo, isto é, um *big bang* a partir do qual tudo teria mudado nas relações sociais organizadas politicamente.

Segundo essas últimas concepções, o(s) Estado(s) teria(m) surgido em diferentes lugares, em épocas distintas, em função das condições concretas de organização política de cada grupo social.

Dividem-se, ainda, os teóricos em duas vertentes:

1. **Naturalismo**, que defende que o Estado sempre existiu na sociedade humana, sendo constituído espontaneamente.
2. **Contratualismo**, que associa o surgimento do Estado a um ato voluntário humano, ou seja, um pacto celebrado entre pessoas que se ajustam no sentido da constituição e da organização política da sociedade civil.

Na atualidade, o processo mais comum de formação do Estado é o **derivado**, isto é, a constituição de novos Estados a partir de Estados preexistentes, o que, via de regra, dá-se por *fracionamento* ou pela *união*.

Dalmo de Abreu Dallari² explica as duas abordagens mencionadas acerca da formação do Estado: o *naturalismo*, de inspiração aristotélica, e o *contratualismo*, que congregou teóricos como Hobbes, Locke e Rousseau, essenciais ao debate, que culminou na formação e na consolidação do Estado moderno.

Segundo a **vertente naturalista**, o homem seria o animal social (*zoon politikon*). Significa que o ser humano é naturalmente gregário, o que, para os naturalistas, tem relação com o fato de que a sociedade civil politicamente organizada não se forma com base em um pacto ou artifício empregado para a saída de um suposto estado de natureza, mas que é organizada *naturalmente* a partir da agregação.

De acordo com Aristóteles:

[...] é evidente que o Estado é uma criação da natureza e que o homem é, por natureza, um animal político. E aquele que por natureza, e não por mero acidente, não tem cidade nem Estado, ou é muito mau ou muito bom, ou sub-humano ou super-humano – sub-humano como o guerreiro insano condenado, nas palavras de Homero, como “alguém sem família, sem lei, sem lar” (Ilíada, IX); porque uma pessoa assim, por natureza amante da guerra, é um não colaborador, como uma peça isolada num jogo de damas. É evidente que o homem é um animal mais político do que as abelhas ou qualquer outro ser gregário. [...] A prova de que o Estado é uma criação da natureza e tem prioridade sobre o indivíduo é que o indivíduo, quando isolado, não é autossuficiente; no entanto, ele o é como parte relacionada com o conjunto. Mas aquele que for incapaz de viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso por ser autossuficiente, será uma besta ou um deus, não uma parte do Estado. Um instinto social é implantado pela natureza em todos os homens.³

Cícero trabalha a ideia aristotélica do animal social e explica que,

mesmo em condições de sobreviver isoladamente, o ser humano possui um instinto de sociabilidade inato que o faz tender à vida em conjunto. Para Cícero, o ser humano não vive em conjunto simplesmente porque sobrevive melhor, isto é, porque seria pretensamente mais apto e forte em grupo, mas vive junto porque tem uma propensão natural a ser gregário.

Tal noção é posteriormente abordada por Santo Tomás de Aquino, para quem a vida solitária é exceção em relação à regra da vida humana em conjunto.

O **contratualismo** foi muito influente no pensamento ocidental até o século XVIII, sendo praticamente deixado de lado no século XIX, tendo em vista a afirmação da supremacia do Estado como instância de poder. A partir da segunda metade do século XX, houve o ressurgimento do contratualismo.⁴ Um dos principais expoentes dessa **retomada do tema** do contrato social na Contemporaneidade foi **John Rawls**, filósofo americano (1921-2002).

Assim como os contratualistas clássicos, Rawls utilizou-se da razão como comportamento político. Todavia, procurou afastar-se da tradição racionalista do Iluminismo, focando na prioridade do *político* em relação à *filosofia*. Em vez de usar categorias de razão de Estado ou da força, Rawls apoiou-se na retórica e na persuasão.

Rawls é considerado expoente do pensamento liberal contemporâneo nos Estados Unidos, estabelecendo a fonte da comunidade política no conceito de **contrato social**.

Diferentemente do contratualismo clássico, em vez de enfatizar o contrato social como mecanismo de superação dos inconvenientes derivados do estado de natureza, o **neocontratualismo** de Rawls focou no contrato como forma de justificar racionalmente princípios que permitam alcançar a justiça e a igualdade (equidade).

Trata-se da utilização da ideia de contrato social para solucionar os problemas de desigualdade na sociedade,⁵ ponto em que Rawls se aproxima parcialmente da pretensão de Rousseau. Este foi um contratualista que procurou prescrever soluções de regeneração social em

bases de igualdade; no entanto, há uma diferença expressiva entre a perspectiva mais comunitária de Rousseau, para quem as pessoas devem se alienar de buscar os interesses particulares em nome da vontade geral, para que conquistem a liberdade civil, em relação ao projeto liberal de Rawls.

Nos dizeres de Catherine Audard, para Rawls, “reintroduzir os imperativos da justiça social não deve suprimir as liberdades e os direitos dos indivíduos”,⁶ mas neles deve fincar raízes, uma vez que a comunidade política é tida como a fonte do contrato social. Exclui-se, portanto, da proposta o argumento pautado na exclusividade da autoridade do Estado, uma vez que o filósofo liberal propõe que a legitimação do regime político seja alicerçada na deliberação racional e autônoma dos indivíduos.

Rawls renuncia, ainda, a falar em **verdade**, daí por que ele não se considera um dogmático. Para resguardar o pluralismo, cria a noção de consenso por justaposição (*overlapping consensus*).

Para Rawls, existem convicções expressas e que são instituições morais básicas partilhadas por quase todos os membros de uma sociedade democrática, por exemplo: a rejeição à escravidão ou à perseguição pautada em motivos políticos, religiosos ou sexuais, bem como a percepção de injustiça derivada das desigualdades de direitos baseadas em arbitrariedade natural ou social.⁷

O contratualismo representou uma instância de justificação do Estado, bem como de limites aos seus poderes, com base em uma tentativa de apoiá-lo no consenso, isto é, na vontade humana.

Mesmo que o contratualismo seja uma ficção, ou ainda um mito fundante, distante da realidade concreta das formações dos Estados, ainda assim a categoria opera da seguinte maneira: parte-se da hipótese de que a sociedade tenha consentido em estruturar o Estado e atribuir-lhe poderes e limites, sendo doravante possível ainda repensar os termos desse ajuste, para amoldá-lo ao que se deseja da (e para a) sociedade.

4.2 Elementos do Estado

Dalmo de Abreu Dallari, na clássica obra *Elementos da teoria geral do Estado*, conceitua o Estado como “ordem jurídica soberana cujo fim é o bem comum de um povo situado em determinado território”.⁸

Trata-se de conceito amplo e útil na medida em que contém quatro elementos básicos da composição do Estado do ponto de vista de sua teoria geral:

1. Soberania.
2. Território.
3. Povo.
4. Finalidade.

4.2.1 Soberania

Soberania representa o poder de autodeterminação plena do Estado, que é capaz internamente de subordinar indivíduos e grupos, e externamente, de ser reconhecido como independente, isto é, não submisso a qualquer potência estrangeira.

O conceito de soberania, como poder supremo do Estado, foi definido teoricamente apenas no século XVI, a partir de Jean Bodin. A necessidade da discussão acerca da soberania ocorreu após os conflitos na Idade Média, em que vários poderes procuravam se afirmar num mesmo território, na tentativa de sobreposição entre os poderes de senhores feudais, do Papa e do monarca.

Jean Bodin, em *Os seis livros da República* (1576), enfatizou que a soberania é o poder perpétuo de uma República,⁹ sendo conferido ao soberano como reflexo do direito divino. Bodin apenas enxergava a limitação da soberania em face de uma lei divina e natural.

Posteriormente, surgiram outras teorias acerca da titularidade da soberania:

- a de Rousseau, que retirou a soberania das mãos exclusivas do governante e a atribuiu ao povo, a partir da defesa da noção de

soberania popular;

- a de Sieyès, para quem a soberania seria da nação e não propriamente do povo, numa tentativa de tornar a categoria mais abstrata, o que reforçava as pretensões burguesas de não atribuir à “plebe” todo poder do Estado;¹⁰ e
- do Estado, como pessoa jurídica, saindo a soberania de um poder político para a titularidade estatal, que foi corrente da segunda metade do século XIX até o século XX, sendo objeto de análise entre os elementos do Estado.

A soberania, do ponto de vista jurídico, é **fundamento** expresso no inciso I do art. 1º da Constituição de 1988, que determina que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito.

Logo, o Estado brasileiro, como pessoa jurídica, é soberano,¹¹ tanto na ordem interna quanto na internacional, sendo tal noção, ainda, associada à soberania popular, pois a legitimidade do poder, num Estado Democrático de Direito, reside no povo, conforme preceito constitucional que determina que: “todo poder emana do povo” (art. 1º, parágrafo único, da Constituição).

4.2.2 Território

Território é o elemento espacial do Estado. Houve, historicamente, várias discussões acerca da natureza jurídica do território. Conforme Dalmo de Abreu Dallari,¹² enquanto Laband enxergava uma relação de domínio do Estado em relação ao território, visto como direito real de natureza pública, Jellinek, por sua vez, acaba negando a relação de domínio, identificando que há um poder de império que se exerce no território. Tal ideia é abordada por Ranelletti, para quem território é o espaço dentro do qual o Estado exerce seu poder de império.

Note-se que na atualidade diferencia-se o domínio eminente que o Estado exerce sobre todas as coisas que estão no seu território, de seu domínio patrimonial. Daí por que não é adequada a abordagem de Laband,

pois não são todas as coisas que estão no espaço territorial do Estado que são de domínio público, mas isso não impede o Estado de exercer poder para condicionar e restringir o uso das propriedades (e liberdades) das pessoas que estão em seu território, no exercício do domínio eminente.

O território nacional abrange os seguintes limites:

- **Marítimo.** Em que há a exploração econômica da plataforma continental, atualmente mensurada em 200 milhas (370,4 km), podendo se estender por 350 milhas (648 km),¹³ se houver cristas submarinas.
- **Solo.**
- **Subsolo.** Que pode ser *ad inferos* (ilimitado).
- **Espaço aéreo.**

4.2.3 Povo

Povo, por sua vez, envolve, para a maior parte dos constitucionalistas, os nacionais, sejam natos ou naturalizados.¹⁴ Trata-se de conceito distinto de população. Enquanto população é um conceito demográfico (geográfico), que expressa o somatório de habitantes de um território, constituído, portanto, tanto de nacionais como de estrangeiros, povo compreende o conjunto de nacionais, que possuem vínculo jurídico-político com o Estado.

Nem todos os nacionais são, do ponto de vista jurídico, cidadãos, pois o exercício pleno da cidadania política se dá com o alistamento eleitoral. Cidadão é, tecnicamente, o nacional munido de título de eleitor, uma vez que somente com esse requisito ele atinge a aptidão plena para o exercício da cidadania.

Logo, o nacional só poderá participar plenamente da vida política de um país quando possuir a idade hábil para votar. De acordo com o art. 14, § 1º, da Constituição, o alistamento eleitoral e o voto são: (1) obrigatórios para os maiores de 18 anos; e (2) facultativos para: analfabetos, maiores de 70 e maiores de 16 e menores de 18 anos.

Apesar de a cidadania, em sentido técnico e mais restritivo, só envolver a faculdade de votar por parte dos nacionais, ainda assim não se pode ignorar que exista um conceito sociológico de cidadania, nem sempre coincidente com o conceito jurídico, sendo aquele mais abrangente do que este último conceito. Na proposta mais abrangente, cidadão é aquele que participa da discussão e das ações que contribuem para a coletividade.

Aliás, nos tempos atuais, também se diz que a cidadania ativa possibilita não apenas a garantia dos direitos previstos no papel, mas é relevante para a criação e o reconhecimento de inúmeros outros direitos.

Também, do ponto de vista sociológico, nem sempre o conceito de nacionalidade corresponde ao de povo, pois, para a Sociologia, nacionalidade envolve identidades étnicas, religiosas e culturais, o que juridicamente não se aplica da mesma maneira.

No caso do Brasil, por exemplo, teríamos sociologicamente várias nações dentro de um mesmo território, mas, para determinados efeitos jurídicos, é melhor que as pessoas do povo¹⁵ sejam indistintamente consideradas nacionais, compreendendo tanto os brasileiros natos ou naturalizados, pouco importando, em geral,¹⁶ para os efeitos da proteção jurídica do direito à nacionalidade,¹⁷ o vínculo étnico e cultural.

4.2.4 Finalidade

Dalmo de Abreu Dallari ainda acrescenta aos três clássicos elementos da teoria do Estado, quais sejam: a soberania, o território e o povo, um quarto elemento: a **finalidade**. Esta se relaciona com as funções que o Estado desempenha, as quais variam entre correntes limitativas, como as liberais, que serão estudadas quando da estruturação do chamado Estado Liberal de Direito, ou expansionistas, por exemplo, aquela do Estado de Bem-Estar Social (*Welfare State*).

Para Dallari, o Estado, isto é, a sociedade política, tem um fim geral de alcançar o bem comum, mas simultaneamente constitui-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam alcançar seus respectivos

fins particulares (uma visão harmônica com a noção de dignidade humana, conforme será visto).

Bem comum, de acordo com a Encíclica *Pacem in Terris*, do Papa João XXIII, que inspira a definição utilizada por Dallari, implica o “conjunto de todas as condições que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”.¹⁸

4.3 Governo

Governo diz respeito ao verbo governar. Também é associado ao governante, isto é, a instância máxima de liderança do Estado. Trata-se do dirigente do Estado. Geralmente se associa governo ao Poder Executivo, daí se desdobrando o governo em: nacional, que engloba todo o território do Estado; regional, quando diz respeito aos estados-membros ou a determinadas regiões; e local, que se refere geralmente ao governo municipal.

Também se diz, no entanto, que a função governamental não é desempenhada somente pelo Poder Executivo e seus ministros, mas, numa democracia, é repartida entre Executivo e Legislativo, pois o Executivo depende da aprovação de leis para viabilizar os planos governamentais em diversos âmbito de atuação.

São duas as principais formas de governo: a República e a Monarquia, sendo também distintos os sistemas de governo, que retratam a divisão e o exercício do poder em âmbito do Estado, desdobrados entre parlamentarismo e presidencialismo.

Enquanto no parlamentarismo há uma interdependência entre os Poderes Legislativo e Executivo, sendo este cindido na Chefia do Estado e na Chefia do Governo, no presidencialismo o Chefe de Governo, que é o Presidente, concentra esses dois papéis. O Chefe de Governo tem distintas denominações nos diversos países que adotam o parlamentarismo, podendo ser o Primeiro-Ministro (Inglaterra) ou, por exemplo, o Chanceler (Alemanha).

- No **presidencialismo** há independência e harmonia entre poderes. **Independência** dos poderes, segundo José Afonso da Silva, significa que:
 - ◆ A investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros;
 - ◆ No exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; e
 - ◆ Na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais.¹⁹
- A **harmonia** confere em certa medida o contraponto da noção de independência, uma vez que indica o dever de colaboração e de controles recíprocos entre os poderes, no qual há o respeito às atribuições e prerrogativas de cada poder sem que ocorra a prevalência de um deles em detrimento dos demais. Contudo, acrescenta com propriedade José Afonso da Silva²⁰ que a harmonia do presidencialismo não se iguala à colaboração de poderes que existe no parlamentarismo, pois neste último sistema de governo não há independência orgânica, mas verdadeira interdependência entre os Poderes Executivo e Legislativo, na qual, por exemplo, o Chefe do Governo depende, para manter-se no poder, do apoio da maioria parlamentar.

Note-se que no Brasil a figura do *impeachment*, inspirada no presidencialismo americano, para ocorrência de crimes de responsabilidade, é utilizada com mais intensidade do que nos Estados Unidos, o que demonstra uma circunstância da necessidade de maior articulação entre Executivo e Legislativo, para que não haja instabilidades práticas.

No Brasil, por conta da fragmentação da representatividade em inúmeros partidos políticos, muitos deles de postura ideológica variável, o Presidente eleito não possui, como regra geral, mais do que 20%²¹ de correspondentes representantes do mesmo partido nas Casas do Congresso

Nacional, o que significa que na prática ele deve, para atingir governabilidade, se esforçar para articular forças políticas para a formação de maiorias.

Trata-se de fragmentação que compromete a governabilidade. Chamada de Presidencialismo de Coalisão, mereceria ser alvo de maiores reflexões numa reforma política mais profunda, para evitar desvios éticos praticados em função dos gargalos do sistema, que não permite o surgimento de um grupo mais coeso e tem por consequência o acirramento do jogo político das trocas de favores (com entrega de ministérios e secretarias) para formação de maioria e aprovação de projetos de lei de interesse do Executivo, numa dinâmica que adiante será chamada de comércio de apoios.

4.4 Governança

Governança é termo introduzido pelo Banco Mundial para discutir as condições para que os Estados fossem eficientes. Foram condições para o financiamento dos Estados, diante da indagação sobre aspectos gerenciais e administrativos do Estado. Governança é desdobramento das ideias de ética e responsabilidade social.

A origem da governança encontra-se na iniciativa privada, no chamado **conflito de agência**. O conflito de agência é um dos componentes da **teoria da firma** ou teoria do principal-agente. Nessa teoria, o principal (acionista ou proprietário) contrata agentes (executivos, conselheiros) para administrar a empresa. Essa é a definição adotada pelo TCU em seu referencial sobre a governança pública.²²

O conflito surge quando os agentes agem em seu próprio benefício, em detrimento dos interesses do proprietário. Quando o proprietário é a multidão de investidores privados de uma sociedade de capital aberto, o conflito de agência se multiplica. A má gestão prejudica esses inúmeros investidores, a reputação do mercado de ações e, no final das contas, a própria sociedade.

- Consórcios.
- Agências reguladoras.

5.1 Organização da Administração Pública: desconcentração e descentralização

A organização administrativa do Estado envolve o estudo da Administração Pública, sua desconcentração e descentralização. Trata-se de assunto relevante para a compreensão da estrutura burocrática e a reflexão de seu tamanho, regime jurídico, conformação normativa e mecanismos de planejamento, articulação e controle.

A estruturação racional da Administração Pública brasileira passou pelas seguintes etapas de destaque: a reforma que resultou na edição do Decreto-Lei 6.016/43; a que deu ensejo à edição do Decreto-Lei 200/67, ainda aplicável a alguns aspectos da Administração, que mais bem disciplinou a Administração Indireta; houve também a iniciativa do Ministério do Planejamento em constituir comissão de juristas¹ da área para elaborar um Anteprojeto da Lei Orgânica da Administração Pública Federal, na época engavetado.

O anteprojeto não logrou êxito, mas procurou resolver alguns problemas identificados na aplicação do Decreto-Lei 200/67, estabelecendo normas gerais sobre a Administração Pública Direta e Indireta, as entidades paraestatais e as de colaboração. Ressalte-se também a criação da Lei das Estatais, Lei 13.303/2016, que disciplinou o regime jurídico próprio das estatais.

Tanto a desconcentração como a descentralização são técnicas utilizadas para racionalizar o desenvolvimento e a prestação de atividades do Estado.

Segundo a clássica definição de Hely Lopes Meirelles,² **desconcentração** é a repartição de funções entre vários órgãos (despersonalizados) de uma mesma Administração, sem quebra da hierarquia.

Na desconcentração, não há a criação de outras pessoas jurídicas, mas a atribuição de determinadas competências a serem distribuídas dentro de uma única pessoa jurídica. Explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro³ que com ela se objetiva descongestionar, desconcentrar, ou seja, tirar do centro um volume grande de atribuições, para permitir um desempenho mais adequado e racional.

São critérios utilizados para a desconcentração, de acordo com a exposição de Celso Antônio Bandeira de Mello:⁴

- em **razão da matéria**, em que há a criação de órgãos para tratar de assuntos determinados, como ocorre, no âmbito federal, nos Ministérios da Justiça, da Saúde, da Educação etc.;
- em **razão do grau**, em que a divisão é feita em função do nível de responsabilidade decisória nos distintos escalões correspondentes aos diversos patamares de autoridade, havendo o diretor de departamento, o diretor de divisão, os chefes de seção, os encarregados do setor etc.; e
- pelo **critério territorial**, cuja base é a divisão de atividades pela localização da repartição, como é o caso das administrações regionais de Prefeitura, da Delegacia Regional da Saúde etc.

As repartições públicas especializadas ou espalhadas por critério territorial são órgãos que compõem a hierarquia da Administração Direta e, como tais, não têm personalidade jurídica própria. São centros especializados de competência que, via de regra, não podem figurar no polo passivo de ações. Assim, os atos que praticam são imputados ao ente estatal ao qual pertencem, e este deve figurar nas ações em geral.

Descentralização, por outro lado, é conceito que envolve a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica, caso em que não se mantém entre elas relação de hierarquia. Nela pressupõe-se a existência de pelo menos **duas pessoas**, entre as quais as atribuições são divididas.

Há duas categorias básicas de **descentralizações**:

1. As **políticas**, estudadas em mais profundidade no Direito constitucional, pois abrangem Entes Federativos (no caso do Brasil: União, estados, Distrito Federal e municípios) com personalidade jurídica de Direito público interno e competências próprias para realizar com autonomia atribuições que decorrem diretamente da Constituição.
2. As **administrativas**, em que um ente central empresta atribuições a órgãos periféricos ou locais dotados de personalidade jurídica. Estas últimas atribuições não decorrem diretamente da Constituição, mas do poder central, que as defere por outorga (lei) ou por delegação (contrato).

As descentralizações administrativas, estudadas no Direito Administrativo, classificam-se em:

- descentralização territorial ou geográfica;
- descentralização por serviços, funcional ou técnica; e
- descentralização por colaboração.

A **descentralização territorial** ou **geográfica** é própria dos países que adotam forma unitária de Estado, como França, Portugal, Bélgica, os quais se dividem em departamentos, regiões, províncias, comunas etc. Nela, há a existência de uma entidade local, geograficamente delimitada, com personalidade própria de Direito público e capacidade genérica. O ente descentralizado tem autoadministração, o que lhe permite exercer a maior parte dos encargos públicos de interesse da coletividade, mas se sujeita ao controle e ingerência do poder central.

No Brasil, são descentralizações geográficas os territórios federais. A Constituição de 1988 extinguiu os territórios federais existentes: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Conforme regras contidas nos arts. 14 e 15 do ADCT, enquanto Roraima e Amapá foram transformados em estados federados, Fernando de Noronha teve sua área reincorporada ao estado de Pernambuco.

Apesar de inexistirem territórios federais, nada obsta que sejam criados

novamente desde que haja disciplina estabelecida em lei complementar, aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar (art. 18, §§ 2º e 3º, da CF).

Ao contrário da disciplina constitucional anterior, a Constituição de 1988 não considera o território federal um Ente Federativo,⁵ apenas uma descentralização territorial que integra a União.

Na **descentralização por serviços**, segundo expõe Maria Sylvia Zanella Di Pietro,⁶ o Poder Público cria ou autoriza a criação por meio de lei de pessoa jurídica de Direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público.

Compreendem os entes da Administração Indireta, isto é, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Di Pietro constata que a Lei 11.107/05 criou também uma nova espécie de descentralização por serviços: o consórcio público, que pode ser constituído como associação pública ou pessoa jurídica de Direito privado para a gestão associada de serviços públicos, conforme determina o art. 241 da Constituição.

Esse tipo de descentralização envolve: reconhecimento da personalidade jurídica do ente descentralizado; existência de órgãos próprios, com certa capacidade de autoadministração; patrimônio próprio; capacidade específica em relação ao serviço público que lhe foi transferido, o que o impede de se desviar dos fins que determinaram sua criação; e sujeição a controle ou tutela exercido pelo ente instituidor, nos limites da lei.

Descentralização por colaboração compreende a transferência da execução de determinado serviço por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, à pessoa jurídica de Direito privado previamente existente. Nesse tipo de descentralização, o Poder Público conserva a titularidade do serviço. São exemplos de descentralização por colaboração a concessão e a permissão de serviços públicos, feitas sempre através de licitação, conforme impõe o art. 175 da Constituição.

5.2 Administração Pública Direta

Compreende as pessoas jurídicas políticas, isto é, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e órgãos que integram tais pessoas por desconcentração, sem personalidade jurídica própria, aos quais a lei confere o exercício de funções administrativas.

O art. 4º do Decreto-Lei 200, de 25.02.1967, com redação dada pela Lei 7.596/87, estipula (para a União) que “a Administração Federal compreende: I – a Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios”.

Segundo a explicação da comissão de especialistas que sugeriu uma reforma da organização administrativa brasileira, a Administração Direta é organizada com base na hierarquia e na desconcentração, e composta por órgãos, sem personalidade jurídica.

A criação e a extinção de órgãos da Administração Direta dependem de lei de iniciativa do Chefe do Executivo. Já a organização e o funcionamento da Administração Direta serão regulados por decreto, que, nos termos e limites da Constituição, e respeitadas as áreas de competência previstas em lei, poderá:

- estabelecer a estrutura interna dos órgãos do Poder Executivo, observada a estrutura básica prevista em lei;
- desmembrar, concentrar ou deslocar ou realocar atribuições de órgãos;
- fazer remanejamento e alterar a denominação de órgãos; e
- redistribuir cargos, empregos e funções entre órgãos.

A Administração Direta, por meio de seus Ministérios, exerce supervisão da Administração Indireta, que, conforme será visto, possui sua personalidade jurídica e estrutura hierárquica própria. Atualmente, a partir do Decreto 8.872/16, a vinculação, por supervisão, em âmbito federal, entre órgãos e Ministérios da Administração Direta e entes da Administração Indireta, conforme abreviatura, é:

1. à Casa Civil: (a) Incra; (b) ITI;
2. à Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos: a EPL; e a Secretaria Especial de Comunicação Social: EBC;
3. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: (a) Ceasa/MG; (b) Casemg; (c) Ceagesp; (d) Conab; e (e) Embrapa;
4. ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações: (a) AEB; (b) Cnen; (c) CNPq; (d) Finep; (e) Ceitec; (f) Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; (g) ECT; (h) Telebras; (i) INB; e (j) Nuclebras-Nuclep;
5. ao Ministério da Defesa: (a) por meio do Comando da Marinha: CCCPM; 2. Emgepron; e 3. Amazul; (b) por meio do Comando do Exército: FHE; Fundação Osório; e Imbel; e (c) por meio do Comando da Aeronáutica: Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica;
6. ao Ministério da Cultura: (a) Ancine; (b) Iphan; (c) Ibram; (d) FBN; (e) FCRB; (f) FCP; e (g) Funarte;
7. ao Ministério da Fazenda: (a) Bacen; (b) Basa; (c) Banco do Brasil; (d) Besc; (e) BEP; (f) BNB; (g) Bescr; (h) CEF; (i) CMB; (j) CVM; (k) Emgea; (l) IRB; (m) Serpro; (n) Susep; (o) Dataprev; e (p) Previc;
8. ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços: (a) FND; (b) Inmetro; (c) Inpi; e (d) Suframa;
9. ao Ministério da Integração Nacional: (a) Sudam; (b) Sudene; (c) Sudeco; (d) Codevasf; e (e) Dnocs;
10. ao Ministério da Justiça e Cidadania: (a) Cade; e (b) Funai;
11. ao Ministério da Saúde: (a) ANS; (b) Anvisa; (c) Hemobras; (d) Funasa; (e) Fiocruz; (f) Hospital Cristo Redentor S/A; (g) Hospital Fêmea S/A; e (h) Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A;
12. ao Ministério das Cidades: (a) CBTU; e (b) Trensurb;
13. ao Ministério das Relações Exteriores: Fundação Alexandre de Gusmão;
14. ao Ministério de Minas e Energia: (a) Aneel; (b) ANP; (c) Eletrobras; (d) CPRM; (e) DNPM; (f) EPE; (g) Petrobras; e (h) PPSA.

15. ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário: INSS;
16. ao Ministério do Meio Ambiente: (a) ANA; (b) Ibama; (c) Instituto Chico Mendes; e (d) JBRJ;
17. ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: (a) Enap; (b) Ipea; (c) IBGE; (d) Funpresp-Exe; (e) ABGF; e (f) BNDES;
18. ao Ministério do Trabalho: Fundacentro;
19. ao Ministério do Turismo: Embratur;
20. ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil: (a) Antaq; (b) ANTT; (c) Anac; (d) Dnit; (e) Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A; (f) Codomar; (g) CDC; (h) Codesa; (i) Codeba; (j) Codesp; (k) CDP; (l) Codern; (m) CDRJ; (n) Infraero;
21. ao Ministério da Educação: (a) Centros Federais de Educação Tecnológica; (b) Colégio Pedro II; (c) Capes; (d) Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; (e) Fundação Joaquim Nabuco; (f) Fundações Universidades; (g) Fundações Universidades Federais; (h) FNDE; (i) HCPA; (j) EBSEERH; (k) Inep; (l) Institutos Federais; (m) Universidades federais; (n) Universidade Tecnológica Federal do Paraná; e (o) Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

Ressalte-se que, em fevereiro de 2017, o Governo Federal criou outros dois órgãos na estrutura da Administração Direta: a Secretaria Geral da Presidência da República e o Ministério dos Direitos Humanos.

5.3 Administração Pública Indireta

Administração Pública Indireta envolve o conjunto de pessoas jurídicas, de Direito público ou privado, criadas por lei, para desempenhar atividades assumidas pelo Estado, seja como serviço público, seja a título de intervenção no domínio econômico.⁷

Envolve, conforme visto, o fenômeno da descentralização por serviços

das atividades estatais, pois a pessoa política faz nascer, por lei, outro ente com personalidade jurídica própria.

A Administração Pública Indireta compreende:

- autarquias;
- fundações públicas;
- sociedades de economia mista;
- empresas públicas; e
- consórcios públicos.

Enquanto as autarquias e fundações públicas possuem o regime jurídico público, as estatais, isto é, sociedades de economia mista e empresas públicas, são regidas pelo Direito privado, sendo parcialmente derogadas pelo Direito público, já os consórcios podem ter natureza pública ou privada.

5.3.1 Autarquia

Autarquia advém do grego *autos-archia*,⁸ que significa “comando de si mesmo” ou “direção própria”. Foi introduzida ao Direito Administrativo inicialmente com o sentido de uma organização que se gera pela vontade do Estado, mas que tem certa autonomia.⁹

Segundo pesquisa de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,¹⁰ o termo foi utilizado pela primeira vez em 1897, por Santi Romano, significando descentralização territorial dos Estados unitários; mas, mesmo nesse sentido originário, não se pode considerar que a descentralização territorial tenha autonomia, pois ela não pode, exceto se houver delegação do poder central, estabelecer seu próprio direito (*autós* = “próprio” e *nómos* = “lei”).

Na atual sistemática constitucional, só são considerados entes autônomos: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 18 da Constituição), porquanto o Brasil constitui uma Federação; o território federal a única possibilidade de descentralização administrativa territorial existente. Não há mais territórios federais no Brasil; mas,

conforme visto, nada impede que sejam criados novos. Territórios federais são descentralizações administrativas geográficas que integram a União e que, diferentemente das descentralizações políticas, não têm autonomia.

No Direito Administrativo brasileiro, autarquia designa uma espécie de **descentralização por serviços**. Trata-se de ente da Administração Indireta.

O art. 5º, I, do Decreto-Lei 200/67 conceitua autarquia como: “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.

O conceito é insuficiente, pois não faz alusão à **natureza jurídica pública** da autarquia. Por conseguinte, a proposta feita pela comissão de especialistas conceitua autarquia como “pessoa jurídica de Direito público, criada por lei específica, para prestar serviço público ou exercer outra atividade administrativa que implique poderes próprios do Estado”.

São características das autarquias:¹¹

- criação por lei;
- personalidade e natureza jurídica públicas;
- capacidade de autoadministração;
- especialização dos fins ou das atividades; e
- sujeição ao controle de tutela.

De acordo com o art. 37, XIX, “somente por lei específica poderá ser criada autarquia”. Como a autarquia somente será **criada por lei específica**, pela regra do paralelismo das formas, sua extinção também só poderá ser feita por lei específica. Note-se que, entre os entes da Administração Indireta, a autarquia é criada por lei enquanto as demais entidades, isto é, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações, devem ter a instituição autorizada por lei.

A autarquia tem **personalidade e natureza jurídica públicas**. De acordo com o art. 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de Direito

público interno: a União; os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; os Municípios; as *autarquias*, inclusive as associações públicas; e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Está expressa, por conseguinte, no art. 41, IV, do Código Civil, a natureza pública da autarquia.

O fato de ter personalidade jurídica faz que a autarquia seja sujeito de direitos e assuma obrigações em nome próprio, respondendo também por seus atos. Como as autarquias têm personalidade de Direito público, expõe José dos Santos Carvalho Filho¹² que sobre elas não incide a disciplina do Código Civil.

Assim, enquanto a existência legal das pessoas de Direito privado começa com a inscrição, no registro próprio, de seus atos constitutivos, a autarquia é regida pelo princípio da legalidade. Como consequência, a personalidade jurídica e existência da autarquia começam com o início de vigência da lei criadora, sem que haja necessidade do ato de registro.

A natureza jurídica pública também lhe confere todas as prerrogativas/poderes e sujeições/deveres decorrentes do regime jurídico administrativo, sendo este assunto do item 1.5.1 da presente obra. Submete-se ao regime jurídico de gestão semelhante ao da Administração Direta, inclusive quanto a atos e processos administrativos, licitações, contratações, bens, servidores públicos, responsabilização, prestação de contas, imunidade tributária e prerrogativas processuais (cf. art. 12 do Anteprojeto de Lei Orgânica).

Apesar de não ter autonomia como os Entes Federativos responsáveis por sua criação, a autarquia tem **autoadministração**. Significa dizer que, como ente jurídico próprio, dotado de personalidade jurídica, ela não se submete às relações hierárquicas da Administração Direta, tendo liberdade para gerir seus quadros sem interferências indevidas.

A autarquia também tem autonomia financeira. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, “seus recursos, não importa se oriundos de trespasse estatal ou hauridos como produto da atividade que lhes seja afeta, configuram recursos e patrimônio próprios”.¹³

A autarquia é criada para descentralizar serviços, sendo-lhe transferida por lei a titularidade de serviço público ou de atividade pública. A pessoa política que deu vida à autarquia lhe destina certa matéria, o que gera **especialização dos fins e atividades**.

Como decorrência, a Administração Direta exerce sobre as autarquias o chamado **controle de tutela**. Esse tipo de controle objetiva verificar se o ente não está se desviando das finalidades que justificam sua existência. Na explicação de Celso Antônio Bandeira de Mello, trata-se do poder que compete à Administração Central de influir sobre as autarquias com o propósito de conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em vista dos quais foram criadas, harmonizando-as com a atuação global do Estado.

No âmbito federal, o controle de tutela denomina-se supervisão ministerial, pois as autarquias se sujeitam à fiscalização do Ministério a cuja pasta esteja vinculada à Presidência da República.¹⁴

As classificações de autarquia¹⁵ utilizam basicamente três critérios: quanto ao âmbito federativo da pessoa que as cria; quanto ao objeto, isto é, o tipo de atividade exercitada; e quanto ao regime jurídico.

Quanto ao **âmbito federativo**, as autarquias podem ser federais, estaduais, distritais e municipais, conforme sejam instituídas respectivamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Como são dotados de autonomia, os Entes Federativos têm competência para organizar sua estrutura administrativa, por meio, por exemplo, da criação de autarquias.

Ressalta José dos Santos Carvalho Filho¹⁶ que não há possibilidade de criação de autarquia interestadual ou intermunicipal, pois, caso haja necessidade de cooperação na gestão associada de serviços públicos, deverá ser celebrado convênio ou consórcio administrativo, nos moldes do art. 241 da Constituição.

Por esse motivo, o STF já considerou que o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDES), entidade comum aos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não poderia ter natureza jurídica de autarquia, mas sim de empresa com personalidade jurídica de

Direito privado, ainda mais porque, além de não haver como criar autarquia interestadual, a matéria de desenvolvimento, planejamento e fomento regional é de competência da União.¹⁷

Quanto ao **objeto** das autarquias, elas podem ser:

- **Assistenciais** ou de **fomento**. Têm por fim realizar os objetivos constitucionais presentes no art. 3º, III, da Constituição, quais sejam: reduzir as desigualdades sociais e regionais. São exemplos a Sudene,¹⁸ a Sudam e o Incra.¹⁹
- **Previdenciárias**. Objetivam operacionalizar políticas públicas e ações da previdência social, administrando recursos e concedendo benefícios. Por exemplo: o INSS²⁰ e, no âmbito do Estado de São Paulo, a SPPREV.²¹
- **Culturais** ou **de ensino**. Desenvolvem políticas e ações voltadas à cultura e à educação, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)²² e as universidades federais, no geral.
- **Profissionais** ou **corporativas**. Criadas pelo Estado para a consecução de fim de interesse público, qual seja a fiscalização do exercício das profissões correspondentes. Para tanto, elas inscrevem e controlam as atividades desenvolvidas em cada segmento profissional. São exemplos de autarquias corporativas: Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina (CRM) e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea). A OAB, na ADI 3.026/DF, de relatoria do Min. Eros Grau, não foi considerada autarquia especial, pois, segundo tal decisão, ela teria objetivos institucionais que transcendem o mero atingimento de finalidades corporativas. Portanto, o Supremo reconheceu para ela um regime jurídico bastante diferenciado (natureza *sui generis*) em relação às demais entidades.
- **Ambientais**. Objetivam promover medidas para preservação da qualidade do meio ambiente, visando ao desenvolvimento sustentável e ao controle/licenciamento de atividades potencialmente degradantes ao meio ambiente, o que não exclui o exercício do poder

sancionatório. São autarquias ambientais: em âmbito federal, o Ibama e, em âmbito estadual, por exemplo: em São Paulo, a Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental), e, no Paraná, o IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

- **De controle.** Para José dos Santos Carvalho Filho,²³ é o caso das agências reguladoras, que têm por fim exercer o controle sobre entidades que prestam serviços públicos, por meio de concessões ou permissões, ou que desenvolvem atividades econômicas.
- **Administrativas.** Categoria residual, desempenham atividades fiscalizatórias próprias do Estado. São exemplos delas: o Inmetro²⁴ e o Bacen.



Figura 5.1 Autarquias no âmbito federativo

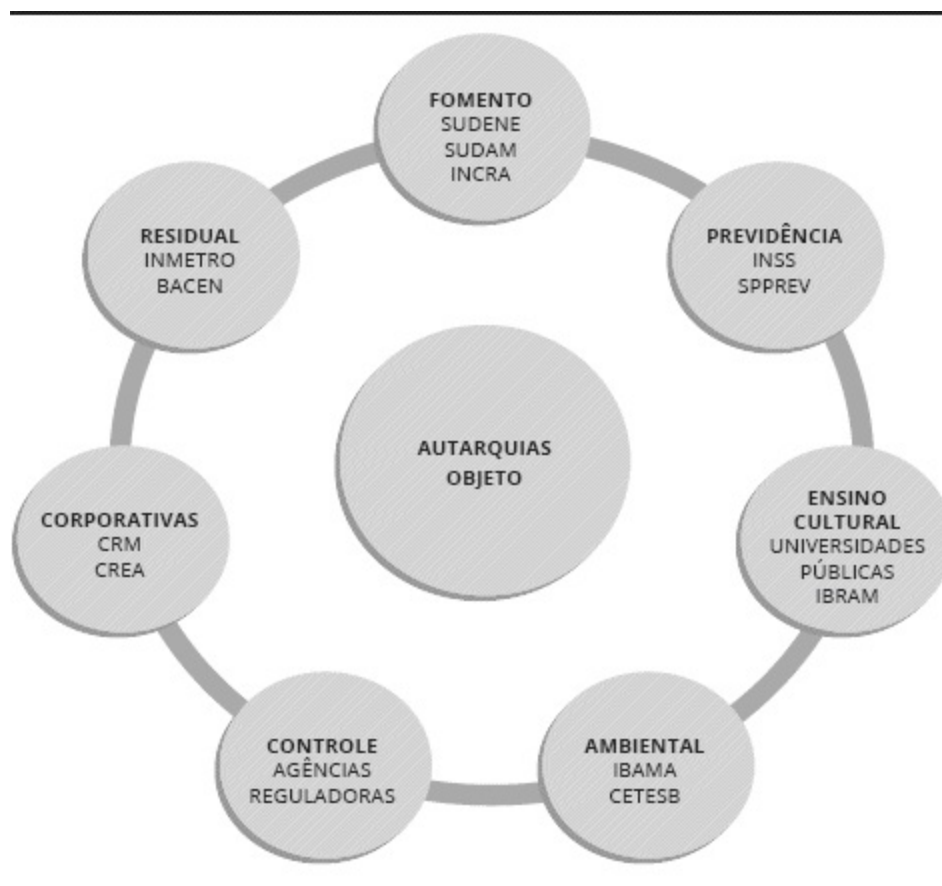


Figura 5.2 Classificação das autarquias quanto ao objeto

Maria Sylvia Zanella Di Pietro²⁵ critica o critério de classificação quanto ao objeto, pois sempre haverá possibilidade de surgir novas autarquias que não se enquadram no rol de atividades. Deve-se ressaltar também que a autarquia, como pessoa jurídica pública, geralmente persegue objetivos públicos, sem finalidades lucrativas.

A classificação quanto ao objeto varia, portanto, em função do tempo,²⁶ pois, se antes havia autarquias de crédito e industriais, como as caixas econômicas e a Imprensa Oficial do Estado, atualmente elas foram transformadas em empresas, uma vez que o Decreto-Lei 200/67 resguardou para os entes autárquicos o desenvolvimento de atividades tipicamente administrativas, excluindo, portanto, de suas atribuições atividades econômicas em sentido estrito.

A classificação dá uma noção das atividades desempenhadas pelas autarquias, mas não é útil para distinguir uma autarquia de outro ente da

Administração Indireta, até porque essa distinção está alicerçada sobretudo no regime jurídico²⁷ do ente.

Quanto ao **regime jurídico**, as autarquias são divididas em autarquias comuns e autarquias especiais. Autarquia em regime especial foi terminologia empregada originariamente pela Lei 5.540/68, que, ao tratar da organização do ensino superior, determinou que as **universidades e estabelecimentos de ensino oficiais** seriam constituídas como autarquias em regime especial ou em fundações de Direito público. Além das universidades públicas, também são consideradas autarquias em regime especial as **agências reguladoras**, conforme será visto.

Já as autarquias sem peculiaridades especiais em seus regimes legais são denominadas autarquias comuns. São aspectos levantados por Odete Medauar²⁸ que demonstram o caráter especial das autarquias universitárias:

- nomeação do reitor pelo Chefe do Executivo com base em lista elaborada pela própria Universidade;
- mandato do dirigente (reitor), insuscetível de cassação pelo Chefe do Executivo (conforme dispõe a Súmula 47 do STF²⁹);
- Estatuto e Regimento elaborados pela própria universidade;
- existência de órgãos colegiados centrais na Administração superior, com funções deliberativas e normativas, dos quais participam docentes, representantes do corpo discente e da comunidade; e
- carreira específica para o pessoal docente, com progressão baseada na obtenção de graus acadêmicos e concursos.

As agências reguladoras têm regime jurídico especial, porque seus dirigentes têm mandato fixo, não sendo livremente exoneráveis pelo Chefe do Executivo. Têm maior autonomia decisória, porquanto é limitada a possibilidade de revisão de seus atos pelo ministério supervisor. Também se costuma apontar o “poder normativo técnico”³⁰ como característica do regime jurídico da agência reguladora, aspecto cuja discussão é controvertida da doutrina, conforme será visto.

Por terem personalidade jurídica de Direito público, as autarquias

possuem todas as prerrogativas ou poderes decorrentes do regime jurídico administrativo.

Assim, praticam **atos administrativos** dotados dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Significa dizer que seus atos, desde que respaldados no ordenamento jurídico, devem ser obedecidos pelos particulares, mesmo contra a vontade deles.

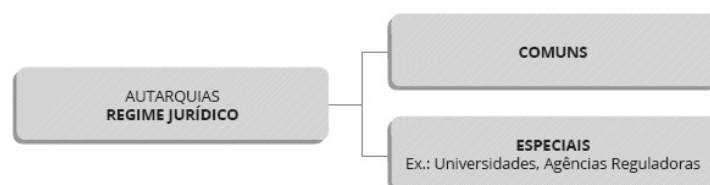


Figura 5.3 Autarquias no regime jurídico

As autarquias gozam de **imunidade recíproca**, ou seja, a regra constitucional impede que as pessoas políticas exijam impostos reciprocamente, umas das outras, sendo prevista para os Entes Federativos no art. 150, VI, *a*, e estendida às autarquias e fundações públicas³¹ instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, conforme o § 2º do mesmo artigo.

O dispositivo afasta a incidência de impostos sobre as autarquias e fundações públicas, federais, estaduais, distritais ou municipais, uma vez que elas desempenham atividades próprias (típicas) da Administração Pública, em razão de personalidade jurídica de Direito público de que são possuidoras e em plena homenagem ao caráter ontológico da imunidade recíproca.³²

O patrimônio, a renda e os serviços somente gozarão da imunidade se forem afetados à realização das finalidades essenciais da autarquia ou delas decorrentes. Essa exigência não é feita para os Entes Federativos. Assim, a *contrario sensu*, se o patrimônio não for destinado à realização das atividades próprias da autarquia, sobre ele deverá incidir imposto.

Note-se que a imunidade recíproca afasta a cobrança de impostos, podendo haver, no entanto, cobrança recíproca dos demais tributos, como taxas e contribuições de melhoria. Mas sobre a taxa cobrada pela autarquia não recai imposto de renda, caso a renda obtida seja destinada às finalidades precípuas do ente da Administração Indireta, conforme se manifestou o STF no julgamento do RE 482814/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º.02.2010, com precedentes em: AC 1.550/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, AC 1.582-MC-QO/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AC 1.549-MC-QO/RO, Rel. Min. Celso de Mello, AC 1.851-QO/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, e RE 598.322/RJ, Rel. Min. Celso de Mello.

As autarquias **não** se sujeitam à **falência**. Elas gozam das mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, quais sejam:

- **prazos processuais diferenciados;**
- créditos executados por procedimento especial de **execução fiscal** regrado pela Lei 6.830/80;
- dívidas cobradas também por procedimento especial de execução amparado no art. 100 da Constituição, referente à ordem cronológica de expedição de ofícios **precatórios**;
- os procuradores de seus quadros são dispensados da exibição ou juntada de instrumento de mandato em juízo, para os atos *ad judicium*;
- as **custas** processuais só serão pagas **no final**, quando vencidas judicialmente;
- restrições quanto à concessão de liminar ou tutela antecipada;
- ausência de sujeição a concurso de credores em falência, salvo no caso de preferência entre Fazendas Públicas (art. 187, parágrafo único, I a III, CTN); e
- **remessa necessária**: a sentença contra elas deferida só poderá ser executada após confirmação pelo tribunal, sendo exigido o duplo grau obrigatório se a autarquia estiver no polo passivo da relação processual, caso em que, se não houver recurso voluntário, deverá ocorrer remessa de ofício à instância superior, ampliadas as exceções

no Novo CPC.

Como decorrência do regime jurídico público, a autarquia se submete às sujeições correspondentes. Seu pessoal deve ser contratado, como regra geral, por concurso público. Os contratos celebrados pelas autarquias devem obediência à Lei de Licitações e Contratos.

As autarquias devem prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo. A responsabilidade da autarquia é objetiva, uma vez que o art. 37, § 6º, da Constituição determina que as pessoas jurídicas de Direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

Ponto controvertido diz respeito ao regime jurídico do pessoal das autarquias. Até a Emenda Constitucional 19/98 havia o estabelecimento do regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública Direta, das autarquias e fundações públicas. Contudo, apesar da tentativa de a reforma acabar com o regime único, ampliando a possibilidade de contratação celetista para a Administração autárquica e fundacional, o regime único foi restaurado com efeitos *ex nunc* por medida cautelar deferida pelo STF na ADI 2.135-4 (DJU 14.08.2007).

Ademais, deve-se enfatizar que seus servidores se submetem: ao regime de teto constitucional (art. 37, XI, CF), conforme será visto, à proibição de acumular cargos, empregos ou funções públicas (art. 37, XVI, CF), bem como às disposições de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, CF, e Lei 8.429/92).

Geralmente, no caso das **autarquias comuns**, a nomeação do dirigente máximo (às vezes denominado também superintendente) ou dos integrantes dos órgãos colegiados de direção superior compete ao Chefe do Poder a que esteja vinculada a entidade, desde que sejam observadas as condições constantes de norma constitucional ou de dispositivo previsto em legislação específica.

Nada impede que a lei estabeleça normas especiais para determinada

autarquia ou categoria de autarquias. Assim, no caso das **autarquias em regime especial**, existem regras específicas para a nomeação dos dirigentes.

Conforme exposto, no caso da autarquia universitária, o reitor é nomeado pelo Chefe do Executivo do mesmo âmbito da autarquia (isto é, se federal, o Presidente da República; se estadual, o Governador), com base em escolha que recai sobre lista elaborada pela própria universidade. Em vez da nomeação por ato simples do Chefe do Executivo, os reitores de universidade são nomeados por “**ato complexo**, do qual participa o colegiado da autarquia (congregação ou conselho), que vota em vários nomes, sendo eleitos integrantes de uma lista, a qual é depois submetida à autoridade ‘de fora’, que escolhe”³³ um dos indicados.

O regime dos bens ou do patrimônio das autarquias é **público**, conforme classificação contida no art. 98 do Código Civil. Ademais, como a autarquia tem personalidade jurídica, os bens são de patrimônio próprio.

São, portanto, consequências do regime dos bens:

- **Inalienabilidade** dos bens enquanto estiverem afetados à destinação pública. Para ser alienados, os bens devem ser desafetados, submetidos à avaliação prévia e à licitação, sendo exigível ainda para os bens imóveis autorização legislativa (art. 17 da Lei 8.666/93).
- **Impenhorabilidade** dos bens afetados às finalidades institucionais, sendo o processo de execução contra a autarquia efetivado pelo procedimento especial do precatório, de acordo com o que dispõe o art. 100 da Constituição, regulamentado pelo art. 910 do CPC.³⁴
- **Imprescritibilidade.** Não sendo, como regra geral, adquiridos pela via da usucapião, uma vez que o parágrafo único do art. 191 da Constituição proíbe usucapião de imóveis públicos e o art. 102 do Código Civil reitera que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
- **Não graváveis com ônus reais.** Proibindo-se que sejam afetados com direitos reais de garantia, como penhor, hipoteca e anticrese.

Quanto às fundações, pode-se dizer que há três tipos básicos de fundações no Direito:

- as fundações de **Direito privado** instituídas **por particulares** – não são objeto do estudo do Direito Administrativo, mas do Direito Civil;
- as fundações de **Direito privado** instituídas **pelo Poder Público**; e
- as fundações de **Direito público**, que têm natureza jurídica de **autarquia**.

5.3.2 Fundações públicas

O tema das fundações públicas é talvez um dos mais controvertidos do Direito Administrativo brasileiro. A maior parte das elaborações doutrinárias sobre o assunto data das décadas de 1970 e 1980.

A Constituição de 1988 contribuiu para pacificar muitos dos debates travados em torno da matéria, pois esclareceu vários pontos obscuros e alguns propositadamente alterados do Decreto-Lei 200/67, por exemplo, pela Lei 7.596/87, conforme será exposto. Atualmente, está em discussão o anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Pública, que modifica a disciplina das fundações.

Costuma-se diferenciar a pessoa jurídica privada³⁵ em duas espécies básicas: as **associações** ou **sociedades**, estudadas antigamente como corporações (*universitas personarum*), constituídas por pessoas que se associam para a consecução de determinados fins *que geralmente as beneficiam*, e as **fundações** (*universitas rerum/bonorum*), que abrangem um conjunto de bens personalizados e destinados a certas finalidades.

O Direito romano clássico só conheceu as corporações.³⁶ Havia corporações *públicas*, como o Estado Romano, o Erário, as Organizações Municipais e as Colônias; e as associações *de caráter privado*, com fins religiosos, econômicos profissionais ou até para garantir um serviço funerário adequado a seus membros.

Os romanos geralmente não atribuíam personalidade jurídica, ou seja, a condição de pessoa, aos patrimônios; havia no máximo a transferência,

inter vivos ou por testamento, de determinado patrimônio para fins de utilidade pública. A ideia surgiu somente no período pós-clássico, com paulatina influência cristã, e consolidou-se na prática de vincular um patrimônio a certas finalidades, especialmente para fins religiosos ou de beneficência (*piae causae*).

Posteriormente, admite-se a possibilidade de haver um patrimônio personalizado, o que significa que o patrimônio ou conjunto de bens passa a ser sujeito de direitos, ou seja, passa a ter aptidão para contrair obrigações jurídicas. Na atualidade, a doutrina é praticamente unânime em definir a fundação como **patrimônio personalizado** destinado a um **fim**.

Muito embora o Direito Administrativo não trate das fundações privadas propriamente ditas, é importante saber as características originárias das fundações privadas para que haja a comparação com as fundações públicas em sentido amplo.

Alguns autores, como José Cretella Júnior,³⁷ entendem que fundação não é categoria do Direito privado, mas sim da Teoria Geral do Direito, pois, em contrapartida às fundações privadas, existem fundações públicas que também fazem parte do gênero das fundações. Contudo, não se pode ignorar o fato de que a teoria das pessoas jurídicas no geral, e especialmente das fundações, foi originada na Idade Média e construída com base em relações privadas, e apenas nos últimos dois séculos a teoria geral do Direito começou a se debruçar sobre o tema das fundações públicas.

No Direito privado, o instituidor da fundação a cria por ato unilateral e irrevogável, isto é, por escritura pública ou testamento com dotação especial de bens livres para tal finalidade (art. 62 do Código Civil). Para entrar no mundo jurídico, a fundação deve ter o estatuto registrado em cartório de registro civil. Apesar de o criador poder declarar a maneira de administrar a fundação, após sua instituição, o instituidor não tem o comando sobre ela.

Os dirigentes da fundação agem em nome e na finalidade da entidade. No Brasil o Ministério Público é, por meio, por exemplo, da Promotoria da

Justiça das Fundações,³⁸ o órgão fiscalizador das fundações (art. 66 do Código Civil). A fiscalização recai, portanto, no Ministério Público do Estado onde estejam situadas as fundações, exceto no caso do Distrito Federal, onde haverá o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.³⁹ O Ministério Público analisa ainda se a dotação contempla bens suficientes para a persecução das finalidades institucionais da fundação.

Se o patrimônio não for suficiente, como por vezes ocorre, a regra do art. 63 do Código Civil de 2002 é que, se não houver determinação do instituidor em sentido diverso, sejam incorporados em outra fundação com fins iguais ou semelhantes. Note-se que o parágrafo único do art. 62 do Código Civil estabelece que a fundação somente poderá constituir-se para fins de:

- assistência social;
- cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- educação;
- saúde;
- segurança alimentar e nutricional;
- defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;
- promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;
- atividades religiosas.

Como a fundação sempre foi vista sob o prisma de um conjunto de bens, seu patrimônio assegura sua existência. Por conseguinte, os bens só podem ser alienados em casos excepcionais e com autorização judicial, jamais podendo ser desviados de sua destinação. O Ministério Público pode pedir a destituição dos dirigentes que não gerirem adequadamente o patrimônio da fundação.

A maior parte da doutrina⁴⁰ e da jurisprudência⁴¹ dos Tribunais Superiores admite que haja **fundação pública de Direito privado**, isto é, fundação instituída pelo Poder Público mas que tenha natureza jurídica privada.

Trata-se, assim como no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, de ente criado pelo Estado com regime privado, mas, pelo fato de ser formado de patrimônio público, seu regime jurídico sofre algumas derrogações de caráter público.

A lei também ressalta a natureza privada da fundação pública, na medida em que o inciso IV do art. 5º do Decreto-Lei 200/67, acrescentado pela Lei 7.596/87, define fundação pública como:

[...] a entidade dotada de personalidade jurídica de Direito privado,⁴² sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de Direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Apesar da natureza privada, a fundação pública não tem fins lucrativos e sua área de atuação obedece ao disposto na lei complementar a que se refere o inciso XIX do art. 37 da Constituição. Note-se que, conforme dito, geralmente se considera que a obtenção de recursos pela entidade, em decorrência da exploração econômica do patrimônio, da venda de bens, da prestação de serviços ou de outras atividades, não descaracteriza seus fins não lucrativos, desde que o resultado das atividades seja integralmente aplicado na realização de seus objetivos.⁴³

Existem várias diferenças entre a fundação de Direito privado instituída por particular e a fundação de Direito privado instituída pelo Poder Público. Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁴⁴ salienta as seguintes distinções:

- enquanto o particular faz um ato de liberalidade e destaca de seu

patrimônio bens destinados a fins alheios, o Poder Público, ao instituir uma fundação, utiliza tal espécie de entidade para atingir determinado fim de interesse público, ou seja, ele se utiliza dela para descentralizar a execução de atividade que lhe compete;

- a fundação criada por particular é instituída por escritura pública ou por testamento, havendo posteriormente a elaboração de seu estatuto; já a fundação de Direito privado instituída pelo Poder Público é criada por autorização legislativa específica, deixando ao estatuto o estabelecimento de parte de suas diretrizes. Contudo, assim como a instituída por particular, ela adquire personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública no registro;
- ao criar uma fundação, seu instituidor privado não tem seu comando, uma vez que ela ganha vida própria; já a fundação pública jamais adquire vida inteiramente própria, pois, se ela é instituída em função do interesse público, pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e do *ius variandi*, que informa a presença de interesses públicos variáveis, o ente que instituiu a fundação pode alterar a lei que autorizou sua criação ou mesmo revogá-la;
- para alterar o estatuto de uma fundação instituída por particular deve haver deliberação de dois terços dos representantes e gestores da fundação (art. 67, I, do Código Civil); no caso da fundação governamental, para alterar a lei que a rege, o Estado não depende de prévia decisão dos órgãos de direção da entidade;
- o ato do instituidor da fundação particular é irrevogável. Já a fundação instituída pelo Poder Público pode ser extinta a qualquer momento, desde que por lei autorizativa nesse sentido, de acordo com o paralelismo das formas; e
- enquanto as fundações instituídas por particulares são fiscalizadas pelo Ministério Público, nas fundações públicas de Direito privado há a supervisão ministerial ou controle de tutela pelos entes da Administração Direta, além da fiscalização financeira e orçamentária. É desnecessário, conforme Di Pietro,⁴⁵ haver duplicidade de controles

com o mesmo objetivo.

As fundações de Direito privado instituídas pelo Poder Público tanto têm um regime diferenciado em relação às fundações inteiramente particulares que o § 3º do Decreto-Lei 200, acrescentado pela Lei 7.596/87, determinou que as fundações públicas “adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações”.

Ora, se a aplicação do Código Civil é adstrita à inscrição da escritura no registro civil de pessoas jurídicas, restam de privado nas fundações públicas de Direito privado os seguintes mecanismos:

- seus bens são penhoráveis, pois são considerados bens privados;
- a lei não a cria, mas, assim como os demais entes privados da Administração Indireta, autoriza sua criação, havendo necessidade, conforme visto, de registro, como as demais pessoas de Direito privado;
- se não desenvolverem serviços públicos (caso em que poderão ser tidas como autarquias fundacionais, conforme será exposto na sequência), serão submetidas à responsabilidade de Direito privado,⁴⁶ em interpretação por exclusão do art. 37, § 6º, da Constituição;
- logo, para o caso das fundações públicas de Direito privado, a fundação responderá até o limite de seu patrimônio, não havendo responsabilidade subsidiária por parte do Estado, como ocorre nos entes de Direito público;
- não têm prerrogativas processuais, como prazos dilatados ou duplo grau obrigatório, próprios das fundações de Direito público do tipo autarquias fundacionais;⁴⁷ e
- o regime de contratação do pessoal é o da CLT; é competente a Justiça do Trabalho para dirimir conflitos dessa natureza.⁴⁸

A Constituição de 1988 pacificou inúmeras questões. Assim, já é certo

que se lhes aplica, como derrogações ao regime privado, uma vez que são criadas pelo Poder Público:

- a fiscalização por parte do **Tribunal de Contas** (art. 71, II);
- seus empregos **não são acumuláveis**, porquanto o art. 37, XVII, determina que “a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, **fundações**, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público”,⁴⁹
- a remuneração paga por tais entes submete-se também às regras de **teto constitucional**, presentes no art. 37, XI, da Constituição;
- seus agentes são considerados “funcionários públicos” para os fins criminais, de impetração de mandado de segurança e ingresso com ação popular e seus dirigentes; caso desempenhem funções delegadas, são considerados autoridades;⁵⁰
- o preenchimento dos empregos deve ser precedido da realização de **concurso público** de provas ou de provas e títulos (art. 37, II), exceto no caso dos cargos em comissão ou de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme exposição do capítulo de agentes públicos;
- submetem-se à **Lei de Licitações** (art. 37, XXI);
- têm **imunidade** tributária em relação aos serviços, bens e rendas vinculados a suas **finalidades essenciais** ou **delas decorrentes** (art. 150, § 2º);
- o foro para processamento e julgamento será o da **Justiça comum estadual**, foro das pessoas privadas, independentemente de ser a fundação federal, estadual, distrital ou municipal; e
- não são **extintas** das formas do Direito privado, mas **por lei**.

Além da fundação de natureza jurídica privada, há a **fundação pública, chamada também autarquia fundacional**.

Se as fundações públicas forem reconhecidas como de Direito público,

aplicam-se-lhes todas as normas decorrentes do regime jurídico da autarquia (expostas de forma pormenorizada anteriormente), sobretudo quanto a: atos e processos administrativos, licitações, contratações, bens, servidores públicos, responsabilização, prestação de contas, imunidade tributária e prerrogativas processuais.

5.3.3 Estatais

Estatal, por sua vez, é toda sociedade, civil ou comercial, da qual o Estado tenha o controle acionário. São espécies do gênero:

- empresas públicas;
- sociedades de economia mista; e
- qualquer outra empresa controlada pelo Estado.

As estatais são pessoas jurídicas de Direito privado, controladas pelo Estado, que tanto podem prestar serviços públicos como explorar atividades econômicas caracterizadas pela produção e comercialização de bens ou pela prestação de serviços em geral, desde que sua atividade esteja respalda nas hipóteses do art. 173 da Constituição.

Enquanto a **empresa pública** é estatal de patrimônio próprio e capital exclusivo, podendo revestir-se de qualquer forma admitida em Direito, a **sociedade de economia mista** é estatal que conta com a participação do Poder Público e de particulares em seu capital e em sua administração, sendo organizada sob a forma de sociedade anônima, conforme será visto.

Ambas as espécies exigem **lei específica** autorizando sua instituição (e extinção – conforme o princípio do paralelismo, ou simetria, das formas) e têm, como dito, **personalidade jurídica de Direito privado**, sendo, não obstante, estatais, isto é, seu controle acionário é do Estado, que as constituiu; por isso elas sofrem algumas **derrogações** de Direito público, por exemplo: exigência de **concurso público** para a contratação de empregados (art. 37, II, da Constituição); submissão à **licitação** com regras próprias, não sendo obrigatória a licitação, como regra geral, para as

atividades-fim; “cabe **mandado de segurança** contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública” (Súmula 333/STJ), porquanto contra atos administrativos das estatais cabe a impetração da medida; os empregados públicos são considerados “funcionários públicos”⁵¹ para **fins penais** (art. 327 do Código Penal), ou seja, respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública; os empregados públicos são agentes públicos, portanto, respondem pela prática de atos de **improbidade administrativa** (art. 1º da Lei 8.429/92); é **vedada a acumulação** de cargos, empregos e funções públicos (art. 37, XVII, da Constituição); se a estatal **receber recursos públicos** para pagamento de despesas de pessoal e para custeio em geral, a ela se aplica o **teto constitucional** de remuneração do inciso XI do art. 37 (art. 37, § 9º, da Constituição); sujeitam-se ao princípio da **especialidade** e, conseqüentemente, ao controle de **tutela**, dentro dos limites legais; e **não se** sujeitam à **falência**, de acordo com o polêmico teor⁵² do art. 2º, I, da Lei 11.101/05.

Quando cria estatais, o Estado geralmente intervém no domínio econômico, desenvolvendo diretamente atividade econômica em sentido estrito. Trata-se da chamada intervenção estatal por participação. Contudo, será visto que há também estatais que prestam serviços públicos.

De acordo com o art. 173 da Constituição, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado **só será permitida** se houver definição legal, quando necessária:

- aos imperativos da **segurança nacional**; ou
- a relevante **interesse coletivo**.

Em uma ordem econômica fundada na livre-iniciativa e no princípio da livre concorrência, a opção do Estado em explorar diretamente atividade econômica no mercado deve ser justificada quando houver razões de importância estratégica relacionadas com a segurança nacional ou de relevante interesse geral.

Apesar de todo o discurso neoliberal, que propugna a “desestatização”, não se pode negar que as empresas estatais também podem cumprir um significativo papel na dinamização da economia de um país, sendo frequentemente indutoras de desenvolvimento, a depender do tipo de atividade e da forma como é desempenhada.

Note-se que até recentemente havia um consenso no sentido de que quando a estatal atua no domínio econômico, seu regime tenderia a ser predominantemente privado, até porque o art. 173, § 1º, II, da Constituição determina que tenham regime jurídico próprio de empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações:

- **civis;**
- **comerciais;**
- **trabalhistas;** e
- **tributários.**

A Emenda Constitucional 19/98, da Reforma Administrativa, pretendeu estabelecer um **estatuto jurídico próprio** para as estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica), em que, além dos direitos e obrigações de caráter privado, seriam disciplinadas regras sobre a função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da Administração Pública; a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; e os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

Também o art. 173, § 2º, da Constituição estabelece que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de **privilégios fiscais** não extensivos às do setor privado”. Se as empresas estatais tivessem benefícios não extensivos às demais empresas privadas que atuam no mercado, elas estariam em vantagem, o que prejudicaria o princípio da livre concorrência no domínio econômico.

Não obstante, nada impede que o Estado, por questões estratégicas, monopolize determinada atividade, caso em que não haverá concorrência. Nessa hipótese, objetiva-se proteger setores estratégicos ao desenvolvimento nacional da especulação privada.

Acrescente-se, ainda, que as estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas) podem prestar serviços públicos, hipótese em que era consensual que o seu regime jurídico acabaria sendo mais público, muito embora a personalidade jurídica continue de Direito privado.

A Lei das Estatais (Lei 13.303, de 30 de junho de 2016), contudo, contrariando a orientação constitucional, criou um regime jurídico que não distingue estatais que atuam no domínio econômico daquelas que prestam serviços públicos, ou seja, houve a disciplina conjunta e homogênea no tratamento legal,⁵³ o que suscitará controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais.

Algumas distinções de regime jurídico possuem, todavia, respaldo constitucional. É o caso, por exemplo, do art. 37, § 6º, da Constituição, que determina que pessoa jurídica de Direito privado, quando prestar serviço público, o que engloba a estatal, responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Apesar do tratamento homogêneo dado às estatais pela lei quando prestam serviços públicos,⁵⁴ há a alteração do seu regime jurídico, mas elas continuam sendo pessoas jurídicas de Direito privado. Portanto, após a autorização legislativa para sua instituição, para que tenham existência jurídica, deve o Poder Executivo providenciar o registro dos atos constitutivos no órgão competente, mesmo que seja uma estatal prestadora de serviço público.

Elas se submetem às derrogações de Direito público mencionadas, aplicáveis a todas as estatais: exigência de concurso público; necessidade de licitação como regra geral; vedação de acumulação de cargos, empregos e funções; responsabilidade penal dos empregados, que respondem também por improbidade administrativa; observância do teto constitucional para a remuneração. A principal marca característica diz

respeito à sua **submissão ao art. 175 da Constituição**, voltado para a prestação de serviço público, e não ao art. 173, que trata da exploração direta de atividade econômica pelo Estado.

O art. 175 da Constituição estipula que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por licitação, a prestação de serviços públicos. Pergunta-se: como no caso da prestação de serviços públicos pelas estatais não será a Administração Direta que desenvolverá a atividade (diretamente), mas sim ente da Administração Indireta (empresas públicas ou sociedades de economia mista), seria necessária delegação contratual, como acontece nos casos de concessão e permissão, para a execução do serviço público?

A resposta é negativa. A lei que autoriza a criação da estatal transfere por outorga a **titularidade** de serviço público (descentralização por serviço), desde que seja atribuição constitucional do ente criador, não sendo, via de regra, necessária a transferência do serviço por contrato, como ocorre nas concessões e permissões de serviços públicos (descentralização por colaboração).

Nesse sentido, pode-se estender o significado do termo *diretamente*, na forma da lei, do art. 175 da Constituição para abarcar também os entes da Administração Indireta prestadores de serviços públicos.

Essa circunstância é excepcionada, como observa Edmir Netto de Araújo, para as hipóteses de estatais criadas para desempenhar serviços cuja titularidade não seja da pessoa política criadora:

[...] por exemplo, a Sabesp, criada para executar serviços de competência regular dos municípios [...]. Opta-se ou por instrumento contratual de concessão, ou pela celebração de convênio, ou ainda, como já se fez, a pessoa política titular outorga legalmente tais serviços à estatal de pessoa política diversa.⁵⁵

Ademais, conforme dito, de acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição, elas acabam se submetendo à **responsabilidade objetiva** pelos danos que seus agentes causarem, uma vez que o dispositivo abarca

“pessoas jurídicas de Direito privado prestadoras de serviços públicos”, sejam elas concessionárias, permissionárias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Já as estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, que atuam, portanto, no domínio econômico (mercado), obedecem ao regime privado de responsabilidade, que é subjetivo (com base na culpa).

Há decisões do STF,⁵⁶ ainda, que garantem à empresa prestadora de serviço público o direito à **imunidade tributária** de que trata o art. 150, VI, *a*, da Constituição, privilégio fiscal cuja extensão é proibida para empresas estatais que atuam no mercado, conforme o art. 173, § 2º, da Constituição.

É polêmica, no entanto, a caracterização do patrimônio da estatal prestadora de serviços públicos. De acordo com o art. 98 do Código Civil, “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de Direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.

José dos Santos Carvalho Filho entende que mesmo os bens de uma estatal prestadora de serviços públicos são considerados privados com destinação especial, ou seja, que “o fato de estarem alguns bens de tais entidades afetados à eventual prestação de serviços públicos não os converte em bens públicos”.⁵⁷

Neste ponto, no entanto, seguimos o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, segundo o qual “são **bens públicos de uso especial** não só os bens das autarquias e fundações públicas, como também os das entidades de Direito privado prestadoras de serviços públicos, desde que afetados diretamente a essa finalidade”.⁵⁸

Essa foi também a orientação do STF em relação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública que presta serviços públicos, que reconheceu a aplicabilidade do “privilégio da impenhorabilidade dos bens, rendas e serviços”⁵⁹ e o regime de precatório.

O regime jurídico dos bens públicos é reconhecido sobretudo pelo fato de que eles estão afetados à realização de importantes funções, daí não

poderem ser penhorados, hipotecados, adquiridos por usucapião, caso em que gerariam a interrupção do serviço público.⁶⁰

Determina o art. 37, XIX, da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que somente por lei específica poderá ser **autorizada a instituição** de empresa pública e de sociedade de economia mista.

A Lei das Estatais esclarece, no art. 2º, § 1º, que a constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo da segurança nacional, conforme exige a Constituição.

Explica Diogenes Gasparini⁶¹ que a lei tanto pode autorizar a criação de estatal como a transformação de outra entidade governamental em empresa estatal, como aconteceu com a Caixa Econômica Federal, que era autarquia e foi transformada em empresa pública. Também pode haver a transformação de uma empresa pública em sociedade de economia mista e vice-versa, desde que autorizado em lei específica.

Assim, não é o fato de o Estado ter adquirido empresa particular e ser seu controlador que a transforma automaticamente em uma sociedade de economia mista, pois há a necessidade de autorização legislativa específica, cuja inobservância gera o reconhecimento da existência de uma simples empresa sob controle acionário do Estado.

Segundo relata Edmir Netto de Araújo,⁶² foi o caso da Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A –, que, independentemente da privatização, foi considerada em 1995 pelo STJ “sociedade anônima, com personalidade jurídica de Direito privado, não podendo transfigurar-lhe em sociedade de economia mista”, pela falta de autorização legislativa (*RDA* 201/198).

A criação cabe ao Poder Executivo ou, quando for o caso, à entidade da Administração Indireta de que a empresa deva ser subsidiária, e o nascimento da pessoa jurídica se subordina ao registro dos estatutos no órgão competente. Assim, rigorosamente falando, a lei específica apenas **autoriza a criação**, mas não cria, pois ela se processa por ato constitutivo do Poder Executivo e transcrição no registro, nos moldes de Direito

privado.

Autorização legislativa específica significa que a lei só envolve esse tema. Trata-se de um mecanismo que objetiva provocar a participação do Poder Legislativo na estruturação da Administração Pública, muito embora a iniciativa da lei seja do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição.

A lei autorizativa permite ao Poder Público, por ato próprio, geralmente decreto, proceder à instituição da entidade. Após aprovados seus atos constitutivos ou estatuto, devem ser arquivados e registrados no órgão próprio. No caso da sociedade de economia mista, que tem natureza jurídica comercial, aplicando-se-lhe a Lei da S/A, é competente a junta comercial para o registro e o arquivamento dos atos constitutivos.

Ressalte-se que também depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias das empresas públicas, assim como a participação delas em empresa privada. O fundamento normativo está contido no art. 2º, § 2º, da Lei das Estatais (Lei 13.303/16), que dispõe depender de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora.

Pelo princípio da simetria ou do paralelismo das formas, se há a necessidade de lei autorizativa para sua criação, também deve haver autorização legal específica para a extinção das estatais. O Poder Executivo não pode, por si, extinguir uma empresa pública ou sociedade de economia mista.

Como o art. 173, § 1º, II, da Constituição determina que as estatais se sujeitam ao regime próprio da empresa privada, inclusive quanto a direitos e obrigações trabalhistas, às empresas públicas e sociedades de economia mista se aplica o regime trabalhista contratual da CLT.

Na realidade, entende-se que o regime contratual é obedecido tanto nas estatais que atuam na economia como nas que prestam serviços públicos. Por conseguinte, os litígios envolvendo tais entidades e seus empregados públicos, decorrentes das relações de trabalho, serão dirimidos na Justiça

do Trabalho, conforme reza o art. 114 da Constituição.

Apesar de ser contratual e privado, o regime sofre, conforme exposto, algumas derrogações de Direito público, uma vez que seus empregados públicos ingressam por concurso público, mas não se lhes é assegurada a estabilidade, que decorre de cargo de provimento efetivo (geralmente estatutário e não trabalhista, conforme será visto no [Capítulo 20](#), no item sobre agentes públicos), respondem por crimes contra a Administração e pela prática de atos de improbidade administrativa, e lhes é vedado o acúmulo de cargos, empregos ou funções, exceto nos casos permitidos pela Constituição (art. 37, XVI e XVII).

Há discussão acerca da dispensa do empregado público. É orientação do Supremo Tribunal Federal que “os empregados admitidos por concurso público em empresa pública ou sociedade de economia mista podem ser dispensados sem motivação, porquanto aplicável a essas entidades o art. 7º, I, da Constituição”.⁶³

Para o caso de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviços públicos, no entanto, há orientação do TST (SDI-I 247) de que “a validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação”.

Os dirigentes das estatais são investidos da forma prevista nos respectivos estatutos ou na lei instituidora, não sendo necessário, conforme decisão do STF,⁶⁴ como é exigido para autarquias ou fundações, a aprovação prévia pelo Poder Legislativo do nomeado pelo Chefe do Executivo.

A Lei das Estatais previu ainda regras mais rigorosas quanto à nomeação de seus dirigentes. Apesar de as estatais desempenharem funções estratégicas para o país, desde a criação muitas delas foram utilizadas em indicações como “cabides de empregos”, isto é, para preencher cargos, numa sistemática de troca de favores/interesses por indicações políticas ou, conforme se revelou mais recentemente no aparelhamento político, com beneficiamento de esquemas entre empresas e políticos, em uma articulação de contratos superfaturados que geravam

propinas e beneficiamento para o apoio a candidaturas, compras de votos etc.

Daí a pressão social pela presença de indicações mais técnicas para os membros do conselho de administração, da diretoria, da presidência e da vice-presidência, para tentar evitar o dito aparelhamento político da Administração Indireta.

Assim, de acordo com a lei, só podem ser indicados para tais cargos cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, que tenham, alternativamente: (a) dez anos de experiência profissional no setor público ou privado de área de atuação da estatal ou em área conexa; (b) quatro anos de três possibilidades: (b1) em direção ou chefia de empresa de porte ou objeto social semelhante ao da estatal; (b2) em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior no setor público; ou (b3) de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da estatal; ou, ainda (c) quatro anos de profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da estatal; e, cumulativamente: formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado e não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade.

Não podem ser indicados para o conselho de administração e para a diretoria: (1) representante do órgão regular ao qual a estatal está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na Administração Pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer Ente da Federação, ainda que licenciados do cargo – ou de parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau deles; (2) de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante da estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral; (3) de pessoa que exerça cargo em organização sindical;⁶⁵ (4) de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, com fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da estatal ou com a própria

empresa ou sociedade.

É possível dispensa dos requisitos previstos no inciso I (número 1 mencionado), se forem atendidas as seguintes exigências: (1) o empregado tenha entrado na estatal por meio de concurso público; (2) o empregado tenha mais de dez anos de trabalho efetivo na estatal; e (3) o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da estatal, comprovando sua capacidade de assumir as responsabilidades para os cargos a que foi indicado.

5.3.3.1 Empresa pública

Empresa pública é espécie de estatal, definida pelo art. 3º da Lei 13.303/2016 da seguinte forma: entidade dotada de personalidade jurídica de Direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de Direito público interno, bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O art. 5º, II, do Decreto-Lei 200/67 (com redação do Decreto-Lei 900/69), por sua vez, define empresa pública como entidade dotada de personalidade jurídica de Direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em Direito.

O capital da empresa pública é **integralmente público**, mas pode pertencer a diversas entidades, desde que sejam de Direito público interno ou integrantes da Administração Indireta,⁶⁶ pois, ao contrário da sociedade de economia mista, a empresa pública não poderá ter patrimônio

integralizado por particulares, pessoas físicas ou empresas privadas.

Ressalte-se que os entes da Administração Indireta, mesmo que de Direito privado, como são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, podem ser titulares do capital de determinada empresa pública, desde que a maioria do capital votante pertença a determinado ente que, no caso federal, é a União.

A empresa pública pode revestir-se de **qualquer das formas** admitidas pelo Direito, o que inclui, por exemplo, sociedades civis, sociedades comerciais, sociedade limitadas, anônimas e até sociedade unipessoal.

5.3.3.2 Sociedade de economia mista

Sociedade de economia mista é empresa estatal, dotada de personalidade jurídica de Direito privado, criada após autorização legal específica, integralizada com a participação do Poder Público e de pessoas físicas e entidades não estatais na formação do capital e na administração, organizada sob a forma de sociedade anônima para o desenvolvimento de atividade econômica ou a prestação de serviços públicos.

Conforme definição contida no art. 4º da Lei 13.303/2016, sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de Direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da Administração Indireta.

O § 1º do art. 4º da Lei 13.303/16 estabelece ainda que a pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador. Aliás, a sociedade de economia mista se submete à Lei das S/A, que é a Lei 6.404/76, e, se tiver registro na Comissão de Valores Mobiliários, sujeita-se também às disposições da Lei 6.385/76.

No Brasil, a primeira sociedade de economia mista criada foi o Banco do Brasil, fundado pelo alvará de 12.12.1808, pelo Príncipe Regente.

Segundo expõe Trajano Valverde, “o alvará fixou as bases de constituição da sociedade de economia mista e lhes outorgou os estatutos”.⁶⁷ Ele desenvolve até hoje atividades no setor bancário.

São também sociedades de economia mista: a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Nordeste, a Brasil Resseguros (IRB) e a Sabesp.

A sociedade de economia mista é regida pelo Direito privado, sofrendo derrogações de Direito público. O capital privado da sociedade de economia mista é captado por ações, por isso é adequada sua forma jurídica de sociedade anônima, mas para que continue sendo estatal a lei confere o controle acionário ao Estado. Ela se submete, não obstante, ao controle estatal denominado tutela.

A Lei das S/A não define a sociedade de economia mista, mas menciona em seus artigos (236 a 240):

- necessidade de prévia **autorização legislativa** para criação e extinção;
- participação **majoritária do Poder Público** no capital;
- obrigatoriedade de existência de **Conselho de Administração**, sendo assegurado à minoria das ações o direito de eleger ao menos um conselheiro – se maior número não couber –, e de **Conselho Fiscal**, com o mesmo direito; e
- obediência ao princípio da **especialidade**, pelo qual as atividades são desenvolvidas em função do objetivo que orienta sua criação.

São basicamente dois aspectos que diferenciam a empresa pública da sociedade de economia mista:

- **o capital:** que na empresa pública é integralmente público e na sociedade de economia mista é misto, isto é, integralizado por dinheiro que vem da iniciativa privada e do Poder Público; e
- **a forma societária:** enquanto a empresa pública pode adotar qualquer configuração societária admitida em direito (ex.: S/A, Ltda. etc.), e até figurino inédito, a sociedade de economia mista só pode adotar a forma de sociedade anônima, submetendo-se à Lei 6.404/76 (com

derrogações de Direito público).

Um dos pontos mais elogiáveis da Lei das Estatais foi a previsão de um sistema de governança corporativa que intensifique a transparência e o controle para minimizar as possíveis falhas de integridade na conduta da alta gestão das estatais.

Houve a incorporação de **parâmetros de governança corporativa**. Segundo determinação da Lei das Estatais, o estatuto social deve determinar que a área de *compliance* se reporte diretamente ao conselho de administração em situações suspeitas do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades, ou quando este se furtar a tomar medidas em situações a ele relatadas.

A lei reconhece a possibilidade de os executivos editarem atos normativos que estabeleçam regras próprias de governança, destinadas às respectivas estatais, desde que isso seja feito em 180 dias de sua publicação. Se não houver regulamentação específica, há a necessidade de submissão às regras de governança nela prevista.

De acordo com o art. 9º da Lei das Estatais, a empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: (1) a ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno; (2) área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; e (3) auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

O **Comitê de Auditoria Estatutário** está previsto no art. 24 da Lei como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual deve se reportar diretamente, competindo-lhe:

- opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
- supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

- supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
- monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;
- avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: (a) remuneração da administração; (b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista; e (c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
- avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas;
- elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;
- avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.

O Comitê deve possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades, possuindo também autonomia operacional e dotação orçamentária para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações, inclusive com a contratação e utilização de especialistas

externos independentes.

Segundo o art. 15 da Lei, o acionista controlador da estatal responderá por abuso de poder nos termos da Lei das S/A, e a ação de reparação pode ser proposta pela sociedade, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da assembleia-geral dos acionistas. Tal ação prescreverá em seis anos, contados da prática do ato abusivo.

5.4 Consórcios

Quanto aos consórcios, há a previsão constitucional no art. 241, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que dispõe:

[...] a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os **consórcios públicos** e os convênios de cooperação entre os Entes Federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

A **Lei 11.107/05** foi criada, após tormentosa polêmica envolvendo também a comunidade científica, para tratar de normas gerais para todos os Entes Federativos que **contratem** consórcios públicos para a realização de interesse comum (art. 1º da Lei).

Justificou-se a criação da Lei de Consórcios, aplicável como regra geral a todos os Entes Federativos, na competência privativa da União para estabelecer **normas gerais de contratação**, nos moldes do art. 22, XXVII, da Constituição.

Muito embora no geral a lei insinue que o consórcio é criado pelo contrato de consórcio, o art. 5º demanda lei ratificadora do protocolo de intenções para que haja a instituição da pessoa jurídica e posterior assinatura do contrato de consórcio.

Assim, o consórcio adquire personalidade jurídica a partir da autorização legal, e não com a mera celebração do contrato, pois no

medida em que sua capacidade de implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da máquina administrativa.

2 As Três Formas de Administração Pública

A reforma do aparelho do Estado tornou-se imperativa nos anos 90 por uma segunda razão. Não apenas ela se constituiu em uma resposta à crise generalizada do Estado, mas também está sendo caracterizada como uma forma de defender o Estado enquanto *res publica*, enquanto coisa pública, enquanto patrimônio que, sendo público, é de todos e para todos.

A defesa da coisa pública vem sendo realizada nas democracias modernas em dois níveis distintos: o nível político e o administrativo. No nível político temos as instituições fundamentais da democracia, através das quais se defendem não apenas os direitos individuais e sociais dos cidadãos, mas também os “direitos públicos” à participação igualitária na coisa pública. As eleições livres e a liberdade de pensamento e de imprensa são formas de defender o cidadão e a coisa pública. A explicitação dos direitos públicos ao patrimônio que é de todos é um passo que está hoje sendo dado em todo o mundo. A denúncia da “privatização” do Estado pela esquerda corresponde à denúncia da direita de que o Estado e a sociedade estão sendo vítimas da prática generalizada do “rent seeking”, da busca de rendas ou vantagens extra-mercados para grupos determinados através do controle do Estado. Ainda no plano democrático, a prática cada vez mais freqüente da participação e controle direto da administração pública pelos cidadãos, principalmente no nível local, é uma nova forma de defender a coisa pública.

No plano administrativo, a administração pública burocrática surgiu no século passado conjuntamente com o Estado liberal, exatamente como uma forma de defender a coisa pública contra o patrimonialismo. Na medida porém, que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais e crescia em dimensão, foi-se percebendo que os custos dessa defesa podiam ser mais altos que os benefícios do controle. Por isso, neste século as práticas burocráticas vêm sendo substituídas por um novo tipo de administração: a administração gerencial.

A reforma do aparelho do Estado não pode ser concebida fora da perspectiva de redefinição do papel do Estado e, portanto, pressupõe o reconhecimento prévio das modificações observadas em suas atribuições ao longo do tempo. Desta forma, partindo-se de uma perspectiva histórica,

verificamos que a administração pública - cujos princípios e características não devem ser confundidos com os da administração das empresas privadas - evoluiu através de três modelos básicos: a administração pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Estas três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada.

Administração Pública Patrimonialista - No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A *res publica* não é diferenciada das *res principis*. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável.

Administração Pública Burocrática - Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre *a priori*. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas.

Por outro lado, o controle - a garantia do poder do Estado - transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Este defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade.

Administração Pública Gerencial - Emerge na segunda metade do século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções

econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da administração pública - a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário - torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.

A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. Isto não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração pública, que continua um princípio fundamental.

Na administração pública gerencial a estratégia volta-se (1) para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, (2) para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados, e (3) para o controle ou cobrança *a posteriori* dos resultados. Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins).

A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas, mas não pode ser confundida com esta última. Enquanto a receita das empresas depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva de impostos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem contrapartida direta. Enquanto o mercado controla a administração das empresas, a sociedade - por meio de

políticos eleitos - controla a administração pública. Enquanto a administração de empresas está voltada para o lucro privado, para a maximização dos interesses dos acionistas, esperando-se que, através do mercado, o interesse coletivo seja atendido, a administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada para o interesse público.

Neste último ponto, como em muitos outros (profissionalismo, impessoalidade, etc.), a administração pública gerencial não se diferencia da administração pública burocrática. Na burocracia pública clássica existe uma noção muito clara e forte do interesse público. A diferença, porém, está no entendimento do significado do interesse público, que não pode ser confundido com o interesse do próprio Estado. Para a administração pública burocrática, o interesse público é freqüentemente identificado com a afirmação do poder do Estado. Ao atuarem sob este princípio, os administradores públicos terminam por direcionar uma parte substancial das atividades e dos recursos do Estado para o atendimento das necessidades da própria burocracia, identificada com o poder do Estado. O conteúdo das políticas públicas é relegado a um segundo plano. A administração pública gerencial nega essa visão do interesse público, relacionando-o com o interesse da coletividade e não com o do aparato do Estado.

A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas.

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à capacitação permanente, que já eram características da boa administração burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados, e da competição administrada.

No presente momento, uma visão realista da reconstrução do aparelho do Estado em bases gerenciais deve levar em conta a necessidade de equacionar as assimetrias decorrentes da persistência de aspectos patrimonialistas na administração contemporânea, bem como dos excessos formais e anacronismos do modelo burocrático tradicional. Para isso, é

fundamental ter clara a dinâmica da administração racional-legal ou burocrática. Não se trata simplesmente de descartá-la, mas sim de considerar os aspectos em que está superada, e as características que ainda se mantêm válidas como formas de garantir efetividade à administração pública.

O modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de comportamentos modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais * oferecidos pelo setor público . A reforma do aparelho do Estado no Brasil significará, fundamentalmente, a introdução na administração pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas.

3 Breve Histórico

3.1 A Reforma do DASP

No Brasil, o modelo de administração burocrática emerge a partir dos anos 30. Surge no quadro da aceleração da industrialização brasileira, em que o Estado assume papel decisivo, intervindo pesadamente no setor produtivo de bens e serviços. A partir da reforma empreendida no governo Vargas por Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes, a administração pública sofre um processo de racionalização que se traduziu no surgimento das primeiras carreiras burocráticas e na tentativa de adoção do concurso como forma de acesso ao serviço público. A implantação da administração pública burocrática é uma consequência clara da emergência de um capitalismo moderno no país.

Com o objetivo de realizar a modernização administrativa, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, em 1936. Nos primórdios, a administração pública sofre a influência da teoria da administração científica de Taylor, tendendo à racionalização mediante a simplificação, padronização e aquisição racional de materiais, revisão de estruturas e aplicação de métodos na definição de procedimentos. Registra-se que, neste período, foi instituída a função orçamentária enquanto atividade formal e permanentemente vinculada ao planejamento.

No que diz respeito à administração dos recursos humanos, o DASP representou a tentativa de formação da burocracia nos moldes weberianos, baseada no princípio do mérito profissional. Entretanto, embora tenham sido valorizados instrumentos importantes à época, tais como o instituto do concurso público e do treinamento, não se chegou a adotar consistentemente uma política de recursos humanos que respondesse às necessidades do Estado. O patrimonialismo (contra o qual a administração pública burocrática se instalara), embora em processo de transformação, mantinha ainda sua própria força no quadro político brasileiro. O coronelismo dava lugar ao clientelismo e ao fisiologismo.

3.2 Rumo à Administração Gerencial

Tendo em vista as inadequações do modelo, a administração burocrática implantada a partir de 30 sofreu sucessivas tentativas de reforma. Não obstante, as experiências se caracterizaram, em alguns casos, pela ênfase na extinção e criação de órgãos, e, em outros, pela constituição de estruturas paralelas visando alterar a rigidez burocrática. Na própria área da reforma administrativa esta última prática foi adotada, por exemplo, no Governo JK, com a criação de comissões especiais, como a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, objetivando a realização de estudos para simplificação dos processos administrativos e reformas ministeriais, e a Comissão de Simplificação Burocrática, que visava à elaboração de projetos direcionados para reformas globais e descentralização de serviços.

A reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei 200, entretanto, constitui um marco na tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Mediante o referido decreto-lei, realizou-se a transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional. Instituíram-se como princípios de racionalidade administrativa o planejamento e o orçamento, o descongestionamento das chefias executivas superiores (desconcentração/descentralização), a tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, a sistematização, a coordenação e o controle.

O paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio estatal na área produtiva de bens e serviços, orientou a expansão da administração indireta, numa tentativa de "flexibilizar a administração" com

o objetivo de atribuir maior operacionalidade às atividades econômicas do Estado.

Entretanto, as reformas operadas pelo Decreto-Lei 200/67 não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática central, permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e competência na administração indireta e formas arcaicas e ineficientes no plano da administração direta ou central. O núcleo burocrático foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através de uma estratégia oportunista do regime militar, que não desenvolveu carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo, ao invés, contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais.

Em meados dos anos 70, uma nova iniciativa modernizadora da administração pública teve início, com a criação da SEMOR - Secretaria da Modernização. Reuniu-se em torno dela um grupo de jovens administradores públicos, muitos deles com formação em nível de pós-graduação no exterior, que buscou implantar novas técnicas de gestão, e particularmente de administração de recursos humanos, na administração pública federal.

No início dos anos 80, registrou-se uma nova tentativa de reformar a burocracia e orientá-la na direção da administração pública gerencial, com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de Desburocratização -PrND, cujos objetivos eram a revitalização e agilização das organizações do Estado, a descentralização da autoridade, a melhoria e simplificação dos processos administrativos e a promoção da eficiência. As ações do PrND voltaram-se inicialmente para o combate à burocratização dos procedimentos. Posteriormente, foram dirigidas para o desenvolvimento do Programa Nacional de Desestatização, num esforço para conter os excessos da expansão da administração descentralizada, estimulada pelo Decreto-Lei 200/67.

3.3 O Retrocesso de 1988

As ações rumo a uma administração pública gerencial são, entretanto, paralisadas na transição democrática de 1985 que, embora representasse uma grande vitória democrática, teve como um de seus custos mais surpreendentes o loteamento dos cargos públicos da administração indireta e das delegacias dos ministérios nos Estados para os políticos dos partidos vitoriosos. Um novo populismo patrimonialista surgia no país. De outra parte, a alta burocracia passava a ser acusada, principalmente pelas

forças conservadoras, de ser a culpada da crise do Estado, na medida em que favorecera seu crescimento excessivo.

A conjunção desses dois fatores leva, na Constituição de 1988, a um retrocesso burocrático sem precedentes. Sem que houvesse maior debate público, o Congresso Constituinte promoveu um surpreendente engessamento do aparelho estatal, ao estender para os serviços do Estado e para as próprias empresas estatais praticamente as mesmas regras burocráticas rígidas adotadas no núcleo estratégico do Estado. A nova Constituição determinou a perda da autonomia do Poder Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos, instituiu a obrigatoriedade de regime jurídico único para os servidores civis da União, dos Estados-membros e dos Municípios, e retirou da administração indireta a sua flexibilidade operacional, ao atribuir às fundações e autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às que regem a administração direta.

Este retrocesso burocrático foi em parte uma reação ao clientelismo que dominou o país naqueles anos. Foi também uma consequência de uma atitude defensiva da alta burocracia que, sentindo-se injustamente acusada, decidiu defender-se de forma irracional.

O retrocesso burocrático não pode ser atribuído a um suposto fracasso da descentralização e da flexibilização da administração pública que o Decreto-Lei 200 teria promovido. Embora alguns abusos tenham sido cometidos em seu nome, seja em termos de excessiva autonomia para as empresas estatais, seja em termos do uso patrimonialista das autarquias e fundações (onde não havia a exigência de processo seletivo público para a admissão de pessoal), não é correto afirmar que tais distorções possam ser imputadas como causas do mesmo. Na medida em que a transição democrática ocorreu no Brasil em meio à crise do Estado, essa última foi equivocadamente identificada pelas forças democráticas como resultado, entre outros, do processo de descentralização que o regime militar procurara implantar. Por outro lado, a transição democrática foi acompanhada por uma ampla campanha contra a estatização, que levou os constituintes a aumentar os controles burocráticos sobre as empresas estatais e a estabelecer normas rígidas para a criação de novas empresas públicas e de subsidiárias das já existentes.

Afinal, geraram-se dois resultados: de um lado, o abandono do caminho rumo a uma administração pública gerencial e a reafirmação dos ideais da administração pública burocrática clássica; de outro lado, dada a ingerência patrimonialista no processo, a instituição de uma série de privilégios, que não se coadunam com a própria administração pública

burocrática. Como exemplos temos a estabilidade rígida para todos os servidores civis, diretamente relacionada à generalização do regime estatutário na administração direta e nas fundações e autarquias, a aposentadoria com proventos integrais sem correlação com o tempo de serviço ou com a contribuição do servidor.

Todos estes fatos contribuíram para o desprestígio da administração pública brasileira, não obstante o fato de que os administradores públicos brasileiros são majoritariamente competentes, honestos e dotados de espírito público. Estas qualidades, que eles demonstraram desde os anos 30, quando a administração pública profissional foi implantada no Brasil, foram um fator decisivo para o papel estratégico que o Estado jogou no desenvolvimento econômico brasileiro. A implantação da indústria de base nos anos 40 e 50, o ajuste nos anos 60, o desenvolvimento da infra-estrutura e a instalação da indústria de bens de capital, nos anos 70, de novo o ajuste e a reforma financeira, nos anos 80, e a liberalização comercial nos anos 90, não teriam sido possíveis não fosse a competência e o espírito público da burocracia brasileira.

As distorções provocadas pela nova Constituição logo se fizeram sentir. No governo Collor, entretanto, a resposta a elas foi equivocada e apenas agravou os problemas existentes, na medida em que se preocupava em destruir ao invés de construir. O governo Itamar Franco buscou essencialmente recompor os salários dos servidores, que haviam sido violentamente reduzidos no governo anterior. O discurso de reforma administrativa assume uma nova dimensão a partir de 1994, quando a campanha presidencial introduz a perspectiva da mudança organizacional e cultural da administração pública no sentido de uma administração gerencial.

4 Diagnóstico

Como resultado do retrocesso burocrático de 1988 houve um encarecimento significativo do custeio da máquina administrativa, tanto no que se refere a gastos com pessoal como bens e serviços, e um enorme aumento da ineficiência dos serviços públicos. Os dados da Tabela 1 e 2 confirmam claramente esta tendência pós-Constituição. Embora tenha havido uma substancial diminuição do número de servidores civis ativos do Poder Executivo da União, que caiu de 713 mil em 1989 para 580 mil em 1995 (Tabela 1), a participação da folha de pagamentos da União no PIB não se reduziu; na verdade, aumentou, passando de 2,89% entre 1980-1987

para 3,17% do PIB na média do período 1988-94 (Tabela 2). O crescimento dos gastos foi ainda muito mais acentuado nos estados e municípios, que passaram a receber uma parcela maior da arrecadação tributária.

O aumento dos gastos com pessoal foi menor na administração federal porque a necessidade de ajuste fiscal, somada à redução relativa de sua participação na receita tributária, levou à suspensão de quase todos os concursos públicos e, portanto, a uma diminuição do número de servidores ativos, visto que os funcionários que se aposentavam não eram substituídos. Na verdade, o que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos é uma mudança no perfil dos servidores: há um crescente número de inativos comparado com o total de ativos.

O contingente de servidores ativos do Poder Executivo - considerando os civis da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e ex-territórios - registrou um declínio nos últimos anos. Em 1988, havia 1.444.000 servidores ativos. Ao final de 1994, eram contabilizados 1.197.000 funcionários. Não dispomos da evolução histórica do número de funcionários dos demais poderes, mas sua participação no total é bem reduzida.

Dada essa redução do número de funcionários, não se pode falar em excesso de quadros na União. O que existe são áreas que concentram um número desnecessário de funcionários e outras que apresentam déficit, como no caso das atividades finais nos setores de saúde e educação.

Além disso, temos que associar esta análise ao processo de descentralização de funções entre os níveis de governo, no âmbito do Estado, e deste para o setor público não-estatal. A composição da força de trabalho no setor público em 1992 (que não deve ter sofrido nenhuma alteração substancial até o presente), no que se refere à sua distribuição entre as três esferas de governo, mostra que os estados empregavam praticamente a soma (49%) do que empregavam municípios (26%) e a União (25%). Este perfil de distribuição, que demonstra uma clara concentração no nível estadual, revela-se a princípio incoerente com a municipalização da execução de serviços, conforme dispõe o texto constitucional.

Tabela 1: Evolução do Número de Servidores do Poder Executivo

	CIVIS ESTATUTÁRIOS*	TOTAL**
--	---------------------	---------

1988	705.548	1.442.657
1989	712.740	1.488.608
1990	628.305	1.338.155
1991	598.375	1.266.495
1992	620.870	1.284.474
1993	592.898	1.258.181
1994	587.202	1.197.460
1995***	580.035	

(*) Civis da Adm. Direta, Autarquias e Fundações; não inclui, portanto os militares.

(**) Inclui, além dos civis estatutários, as empresas públicas e as sociedades de economia mista

(***) Posição de março

Fonte: SRH / MARE - SEST/MPO

Tabela 2: Evolução dos Gastos da União e dos Estados e Municípios
(em % do PIB)

	<i>União</i>	<i>Est. e Munic.</i>
Média anual 70/79	3,41	3,87
Média anual 80/87	2,89	4,18
Média anual 88/94	3,17	6,53

Fonte: IBGE

4.1 Perguntas Básicas

O diagnóstico da administração pública brasileira envolve a resposta a algumas perguntas básicas:

(1) O Estado deve permanecer realizando as mesmas atividades? Algumas delas podem ser eliminadas? Ou devem ser transferidas da União para os estados ou para os municípios? Ou ainda, devem ser transferidas para o setor público não-estatal? Ou então para o setor privado?

(2) Por outro lado, dadas as novas funções, antes reguladoras que executoras, deve o Estado criar novas instituições?

(3) Para exercer as suas funções o Estado necessita do contingente de funcionários existente? A qualidade e a motivação dos servidores são satisfatórias? Dispõe-se de uma política de recursos humanos adequada?

(4) As organizações públicas operam com qualidade e eficiência? Seus serviços estão voltados prioritariamente para o atendimento do cidadão, entendido como um cliente, ou estão mais orientadas para o simples controle do próprio Estado?

Para responder as estas perguntas será necessário um trabalho amplo e permanente de avaliação do setor público brasileiro. Um trabalho que foi em parte realizado no governo de transição, quando dois ministérios foram extintos e diversos órgãos reestruturados ou mesmo criados. Está claro, porém, que ainda há muito a fazer. Na verdade, o que está se iniciando é uma ampla reforma administrativa, para a qual este Plano Diretor estabelece as diretrizes.

No esforço de diagnóstico da administração pública brasileira centraremos nossa atenção, de um lado, nas condições do mercado de trabalho e na política de recursos humanos, e, de outro, na distinção de três dimensões dos problemas: (1) a dimensão institucional-legal, relacionada aos obstáculos de ordem legal para o alcance de uma maior eficiência do aparelho do Estado; (2) a dimensão cultural, definida pela coexistência de valores patrimonialistas e principalmente burocráticos com os novos valores gerenciais e modernos na administração pública brasileira; e (3) a dimensão gerencial, associada às práticas administrativas. As três dimensões estão inter-relacionadas. Há uma tendência a subordinar a terceira à primeira, quando se afirma que é impossível implantar qualquer reforma na área da gestão enquanto não forem modificadas as instituições, a partir da Constituição Federal. É claro que esta visão é falsa. Apesar das dificuldades, é possível promover já a mudança da cultura administrativa e reformar a dimensão-gestão do Estado, enquanto vai sendo providenciada a mudança do sistema legal.

4.2 Dimensão Institucional-Legal

Na história brasileira, registram-se movimentos de reforma administrativa identificados com a fusão, extinção e criação de órgãos. Estas mudanças, que revelam uma grande instabilidade do organograma governamental, não evitaram a manutenção de estruturas obsoletas, pesadas e hierarquizadas, pouco dinâmicas e excessivamente caras, sobretudo devido à tendência à centralização e à superposição de órgãos e de funções.

Em 1988, num esforço de impedir o arbítrio e fortalecer as instituições democráticas, a Constituição, por força do que dispôs o artigo 48, inciso XI, retirou a competência exclusiva do Poder Executivo para

atuar na organização da administração pública no tocante à estruturação dos órgãos públicos. Este fato criou sérios obstáculos à modernização das organizações do Estado, sem impedir que a mudança das estruturas continuasse a ser submetida a critérios políticos indesejáveis.

Visando maior racionalização no uso de recursos, a Constituição de 1988 assegurou como princípio administrativo a descentralização da execução dos serviços sociais e de infra-estrutura, bem como dos recursos orçamentários para os estados e municípios. Conseqüentemente, estes últimos aumentaram sua participação na repartição da carga tributária. Entretanto, os avanços no sentido de conceder maior autonomia na execução de serviços e de favorecer as unidades subnacionais caminham lentamente, menos por falta de definição legal do problema, e mais pela crença arraigada na cultura política brasileira de que cabe à União promover diretamente o desenvolvimento social do país. Esta crença está em contradição com a profunda tradição municipalista brasileira, que vem do período colonial, e aos poucos vai sendo abandonada, à medida em que os municípios, melhor dotados de recursos financeiros, vêm assumindo crescentes responsabilidades na área social.

O modelo burocrático tradicional, que a Constituição de 1988 e todo o sistema do Direito Administrativo brasileiro privilegiam, está baseado no formalismo, no excesso de normas e na rigidez de procedimentos. A pretexto de garantir a impessoalidade, dificulta-se a transparência administrativa, inibindo-se deste modo o controle social. A excessiva regulamentação é expressão da ênfase nas normas e processos, e ocorre em detrimento dos resultados.

A rigidez da estabilidade assegurada aos servidores públicos civis impede a adequação dos quadros de funcionários às reais necessidades do serviço, e dificulta a cobrança de trabalho. Da mesma forma, a transformação do concurso público - cuja exigência generalizada na administração pública representou o grande avanço da Constituição de 1988 - em uma espécie de tabu dificulta as transferências de funcionários entre cargos de natureza semelhante. Por outro lado, as exigências excessivas de controles no processo de compras e o detalhismo dos orçamentos são exemplos dessa perspectiva burocrática implantada na lei brasileira, que dificultam de forma extraordinária o bom funcionamento da administração pública. Destaca-se a deficiência de sistemas de informação e a inexistência de indicadores de desempenho claros para os diversos órgãos da administração direta e indireta.

4.3 Recursos Humanos

A legislação brasileira reflete a ausência de uma política de recursos humanos coerente com as necessidades do aparelho do Estado. É, em princípio, o aspecto da administração pública mais vulnerável aos efeitos da crise fiscal e da política de ajuste.

A legislação que regula as relações de trabalho no setor público é inadequada, notadamente pelo seu caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor. São exemplos imediatos deste quadro a aplicação indiscriminada do instituto da estabilidade para o conjunto dos servidores públicos civis submetidos a regime de cargo público e de critérios rígidos de seleção e contratação de pessoal que impedem o recrutamento direto no mercado, em detrimento do estímulo à competência.

Enumeram-se alguns equívocos da Constituição de 1988 no campo da administração de recursos humanos. Por meio da institucionalização do Regime Jurídico Único, deu início ao processo de uniformização do tratamento de todos os servidores da administração direta e indireta. Limitou-se o ingresso ao concurso público, sendo que poderiam ser também utilizadas outras formas de seleção que, tornariam mais flexível o recrutamento de pessoal sem permitir a volta do clientelismo patrimonialista (por exemplo, o processo seletivo público para funcionários celetistas, que não façam parte das carreiras exclusivas de Estado).

Os concursos públicos, por outro lado, são realizados sem nenhuma regularidade e avaliação periódica da necessidade de quadros, fato que leva à admissão de um contingente excessivo de candidatos a um só tempo, seguida de longos períodos sem uma nova seleção, o que inviabiliza a criação de verdadeiras carreiras.

Além disso, a extensão do regime estatutário para todos os servidores civis, ampliando o número de servidores estáveis, não apenas encareceu enormemente os custos da máquina administrativa, mas também levou muitos funcionários a não valorizarem seu cargo, na medida em que a distinção entre eficiência e ineficiência perde relevância. Como os incentivos positivos são também limitados - dada a dificuldade de estabelecer gratificações por desempenho, e o fato de que a amplitude das carreiras (distância percentual entre a menor e a maior remuneração) foi violentamente reduzida, na maioria dos casos não superando os 20% -, os administradores públicos ficaram destituídos de instrumentos para motivar seus funcionários, a não ser as gratificações por ocupação de cargos em comissão (DAS). A redução da amplitude de remuneração das carreiras,

inclusive de algumas mais recentes como as dos analistas do Tesouro, dos analistas de orçamento e dos gestores, reduziu as mesmas, na verdade, a meros cargos, ao eliminar uma das características típicas das carreias, que é o estímulo à ascensão ao longo do tempo.

Do ponto de vista dos quadros técnicos, gerenciais e operacionais, observa-se que a administração de recursos humanos carece da existência de um sistema de incentivos para o profissional, sendo patente a ausência de uma política orgânica de formação, capacitação permanente e de remuneração condizente com a valorização do exercício da função pública.

O perfil da distribuição de servidores em carreias apresenta sérias distorções. Do total de funcionários civis estatutários, cerca de 47% estão agrupados fora de carreias específicas, sem definição de atribuições, alocados no Plano de Cargos e Carreias - PCC. Ressalta-se, ainda, uma concentração de pessoal nos níveis operacionais, sendo o quadro técnico, representante da inteligência do Estado, bastante reduzido.

Consideram-se carreias estruturadas apenas a Diplomacia, o Magistério e as dos Militares. São aquelas que possuem uma amplitude entre o piso e o teto salarial (entre a menor e a maior remuneração) que estimula o servidor a buscar a ascensão funcional e possibilita a prática de políticas de promoção baseadas em avaliações de desempenho, conforme podemos observar na Tabela 3. Outras carreias, como as dos Procuradores, da Polícia Federal, Receita Federal, Finanças, Controle e Orçamento e dos Gestores têm alguma estruturação, mas sua amplitude de remuneração é pequena.

Tabela 3: “Amplitude” das Carreias da Administração Federal*

CARGO / CARREIRA	AMPLITUDE %
ORÇAMENTO / FINANÇAS E CONTROLE	
Analista	26
Técnico	44
ESPEC. EM POLÍTICAS E GESTÃO GOVERN.	
Gestor	26

AUDITORIA	
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional	6
Técnico do Tesouro Nacional	12
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	
Procurador 2ª Categoria a Procurador 1ª Categoria / Subprocurador de Categoria Especial	8
DIPLOMACIA	
3º Secretário a Ministro 1ª Classe	51
CARREIRA DE DOCENTE (SUPERIOR - 40 H)	
Professor Auxiliar a Titular	222
CARREIRA DE PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
Assistente de Pesquisa a Pesquisador Titular	114
MILITARES	
Segundo Tenente a Almirante de Esquadra	181

Fonte: MARE / SIAPE.

Posição de julho/95

Observação: “Amplitude” de uma carreira é a diferença percentual entre a menor e a maior remuneração dessa carreira.

A administração pública brasileira, embora marcada pela cultura burocrática e regida pelo princípio do mérito profissional, não chegou a se consolidar, no conjunto, como uma burocracia profissional nos moldes weberianos. Formaram-se grupos de reconhecida competência, como é o caso das carreiras acima descritas, bem como em áreas da administração indireta, mas os concursos jamais foram rotinizados e o valor de sua remuneração real variou intensamente em função de políticas salariais instáveis. Os instrumentos de seleção, avaliação, promoção e treinamento que deram suporte a esse modelo estão superados.

Embora seja possível interpretar que a Constituição de 1988 e o Regime Jurídico Único tenham originalmente tentado preservar a administração, evitando a utilização política dos cargos e promovendo a valorização através da proteção ao servidor, o que se observa de fato é que

contribuíram para restringir a capacidade operacional do governo, ao dificultar a adoção de mecanismos de gestão de recursos humanos que sejam baseados em princípios de valorização pelo efetivo desempenho profissional e também eficazes na busca da melhoria dos resultados das organizações e da qualidade dos serviços prestados.

4.4 O Mercado de Trabalho no Setor Público

As condições do mercado de trabalho no setor público também desempenham um papel importante na gestão de recursos humanos do Estado e, conseqüentemente, em seu próprio processo de modernização, na medida em que podem definir o grau de estímulo ao ingresso neste mercado para profissionais com boa formação e treinamento e recém-formados que se demonstrem competentes. Neste sentido, vamos analisar a relação entre a crise fiscal, a dinâmica deste mercado e o comportamento da remuneração dos servidores, e traçar uma comparação entre as estruturas salariais dos setores público e privado.

4.4.1 Crise Fiscal e Gastos com Ativos e Inativos

A participação dos gastos com pessoal na receita da União vem apresentando uma tendência histórica crescente. A partir da Tabela 4, podemos observar que a participação dos gastos globais com pessoal na receita disponível (que corresponde à receita tributária bruta, descontada dos incentivos fiscais e das transferências legais e constitucionais), sofreu um incremento nesta década em relação aos valores observados nos anos 80, em grande parte devido à Constituição de 1988. A partir de 1990, tem se mantido no intervalo entre 55 e 60% .

Tabela 4: Participação dos Gastos com Pessoal na Receita Disponível **

MÉDIA 82-84	38,4%
MÉDIA 85-87	40,6%
MÉDIA 88-89	50,9%
1990	60,1%
1991	57,9%
1992	57,2%
1993	60,4%
1994	56,1%
1995*	60,4%

federais. Em segundo lugar, a remuneração global dos detentores de DAS obedece a uma escala crescente, aproximando-se de um sistema de carreira.

Tabela 9: Ocupantes de DAS

	<i>Qtde. Servidores</i>	<i>Idade Média</i>	<i>Sexo Feminino</i>	<i>Nível Superior</i>	<i>Servidores Públicos</i>	<i>Remuneração Média *</i>
DAS-1	7.206	41	45,2%	50,8%	78,5%	2.665
DAS-2	5.661	42	39,0%	61,8%	77,7%	3.124
DAS-3	2.265	44	36,0%	71,0%	71,4%	3.402
DAS-4	1.464	46	28,8%	81,3%	65,4%	4.710
DAS-5	503	48	17,3%	86,1%	60,6%	6.018
DAS-6	128	50	16,4%	85,9%	48,4%	6.339
TOTAL	17.227	42	39,5%	61,0%	75,5%	3.112

Fonte: SIAPE

* Inclui remuneração do cargo e da função; estão considerados no cálculo dos valores desta coluna somente os servidores efetivos

A lei que no início de 1995 aumentou o valor nominal dos DASs de 4 a 6 e a retribuição dos Cargos de Natureza Especial, ao determinar que a remuneração de origem dos servidores fosse descontada, apenas aperfeiçoou ainda mais esse sistema. Na verdade, o sistema de DASs, ao flexibilizar a estrutura rígida e distorcida do sistema remuneratório brasileiro, é um passo na direção de uma administração pública gerencial. Os DASs são ocupados a partir de um verdadeiro mercado, no qual os ministros e dirigentes públicos que dispõem de DASs disputam entre si os melhores quadros do serviço federal. Desta forma se premiam os mais competentes. Certamente existem distorções no sistema, derivadas da consignação de DAS para pessoas sem mérito, geralmente provenientes de fora do serviço público. Estas distorções, entretanto, são a exceção e não a regra. Uma exceção cuja ocorrência será cada vez mais rara à medida em que um número alto e crescente de DASs seja reservado por lei a servidores federais.

4.5 Dimensão Cultural e Dimensão-Gestão

Os problemas até agora analisados estão fortemente relacionados com sua dimensão institucional-legal, dependendo, portanto, de reforma constitucional, ou de mudança na legislação infra-constitucional, mas todos esses entraves estão diretamente relacionados com a cultura burocrática existente no país, intensamente preocupada em evitar as práticas

clientelistas ou patrimonialistas. Como sabemos, historicamente a dominação racional-legal ou burocrática surgiu no século XIX como uma forma superior de dominação, legitimada pelo uso da lei, em contraposição ao poder tradicional (divino) e arbitrário dos príncipes e ao afeto das lideranças carismáticas. Surgiu, portanto, como uma reação à cultura patrimonialista, então dominante. Sua afirmação implicou o desenvolvimento, no nível da administração pública, de uma cultura burocrática, que, no plano político, correspondeu à prevalência do Estado liberal e à correspondente ideologia liberal, que o direito administrativo expressa bem.

Esta cultura burocrática não reconhece que o patrimonialismo, embora presente como prática, já não constitui mais valor hoje no Brasil. Não reconhece que os políticos, em uma democracia, são crescentemente controlados por seus eleitores. Por isso, ela mantém uma desconfiança fundamental nos políticos, que estariam sempre prontos a subordinar a administração pública a seus interesses eleitorais. Na prática, o resultado é uma desconfiança nos administradores públicos, aos quais não se delega autoridade para decidir com autonomia os problemas relacionados com os recursos humanos, materiais e financeiros. Explica-se daí a rigidez da estabilidade e dos concursos, o formalismo do sistema de licitações, e o detalhismo do orçamento. Esses obstáculos a uma administração pública eficiente só poderão ser superados quando, conjuntamente com a mudança institucional-legal ocorra uma mudança cultural no sentido da administração pública gerencial.

A dimensão institucional-legal e a dimensão cultural dos entraves a uma administração pública moderna, gerencial, eficiente e voltada para o atendimento do cidadão complementam-se com a dimensão-gestão. Na verdade, é nesta última que a administração pública demonstra sua energia, pois sua eficiência e efetividade dependerão da capacidade de gestão nela existente.

Esta dimensão diz respeito a um elemento central da técnica administrativa de como fazer, com que métodos, de que modo, sob orientação de quais valores. A boa gestão é aquela que define objetivos com clareza, recruta os melhores elementos através de concursos e processos seletivos públicos, treina permanentemente os funcionários, desenvolve sistemas de motivação não apenas de caráter material mas também de caráter psicossocial, dá autonomia aos executores e, afinal, cobra os resultados. Nada disto existe na administração pública federal.

O modelo burocrático implantado no país soma aos defeitos inerentes à administração pública burocrática, relacionados com o controle rígido dos processos, a falta de treinamento e de estrutura de carreiras que, pelo contrário, caracterizam as boas burocracias ainda existentes em países como a França e o Japão. Os instrumentos de supervisão e acompanhamento são pouco criativos, sendo deste modo insuficientes para caminhar passo a passo com a mudança tecnológica e atender à necessidade de repensar e propor novos objetivos e métodos de forma ágil, em menor tempo e a um custo mais baixo. Além disso, o sistema carece de mecanismos auto-reguladores e é refratário às inovações. Sua capacidade de resposta aos novos e constantes estímulos é limitada, fato que o torna arcaico e ineficiente.

O mecanismo por excelência de motivação, na administração pública burocrática, é o da promoção por mérito em carreiras formalmente estabelecidas. Através desse mecanismo, em que o tempo, além dos cursos, a avaliação de desempenho e os exames são essenciais, o administrador ascende lentamente na sua profissão. Dada, entretanto, a dinâmica do desenvolvimento tecnológico das sociedades contemporâneas, esse sistema de carreira foi se tornando crescentemente superado. Os jovens administradores não estão dispostos a esperar o alcance dos 50 anos para ocuparem cargos de direção. Por outro lado, a instabilidade do sistema político e administrativo brasileiro dificultou adicionalmente o desenvolvimento de carreiras. Mesmo as novas carreiras, criadas na segunda metade dos anos 80, como as dos gestores e dos analistas de finanças e orçamento, tiveram sua amplitude de remuneração rapidamente reduzida, para permitir o acesso dos jovens. O sistema de premiação e motivação dos funcionários públicos foi crescentemente identificado com a ocupação de cargos em comissão.

Torna-se, assim, essencial repensar o sistema de motivação dos servidores públicos brasileiros. Não há dúvida que a motivação positiva fundamental é aquela relacionada com o sentido de missão do servidor. Para o servidor público é mais fácil definir esse sentido do que para o empregado privado, já que a atividade do Estado está diretamente voltada para o interesse público, enquanto que a atividade privada só o está indiretamente, através do controle via mercado. Entretanto, em momentos de crise e de transição como o que vivemos, o papel do Estado e do servidor público ficam confusos. A idéia burocrática de um Estado voltado para si mesmo está claramente superada, mas não foi possível ainda implantar na administração pública brasileira uma cultura de atendimento ao cidadão-cliente.

A segunda motivação é a da profissionalização do serviço público, não apenas através de concursos e processos seletivos públicos, mas principalmente através de um sistema de promoções na carreira em função do mérito acompanhadas por remuneração correspondentemente maior. Esta motivação é fundamental, mas já vimos que não pode ter a rigidez peculiar às carreiras burocráticas. É preciso garantir a profissionalização sem a correspondente rigidez da burocracia.

Finalmente é essencial contar-se com uma motivação negativa, possibilitada através da demissão por insuficiência de desempenho. Embora secundária em relação às motivações positivas, não há dúvida que sem ela será muito difícil, senão impossível, levar o funcionário comum a valorizar o seu emprego.

O diagnóstico mostra que para uma reforma consistente do aparelho do Estado necessita-se, hoje, mais que um mero rearranjo de estruturas. A superação das formas tradicionais de ação estatal implica descentralizar e redesenhar estruturas, dotando-as de inteligência e flexibilidade, e sobretudo desenvolver modelos gerenciais para o setor público capazes de gerar resultados.

A modernização do aparelho do Estado exige, também, a criação de mecanismos que viabilizem a integração dos cidadãos no processo de definição, implementação e avaliação da ação pública. Através do controle social crescente será possível garantir serviços de qualidade.

5 O Aparelho do Estado e as Formas de Propriedade

Para enfrentar os principais problemas que representam obstáculos à implementação de um aparelho do Estado moderno e eficiente, torna-se necessário definir um modelo conceitual, que distinga os segmentos fundamentais característicos da ação do Estado. A opção pela construção deste modelo tem como principal vantagem permitir a identificação de estratégias específicas para cada segmento de atuação do Estado, evitando a alternativa simplista de proposição de soluções genéricas a problemas que são peculiares dependendo do setor. Entretanto, tem a desvantagem da imperfeição intrínseca dos modelos, que sempre representam uma simplificação da realidade. Estas imperfeições, caracterizadas por eventuais omissões e dificuldades de estabelecimento de limites entre as fronteiras de cada segmento, serão aperfeiçoadas na medida do aprofundamento do debate.

O Estado é a organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar sobre a população de um determinado território. O Estado é, portanto, a única estrutura organizacional que possui o “poder extroverso”, ou seja, o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios limites.

O aparelho do Estado ou administração pública lato senso, compreende (a) um núcleo estratégico ou governo, constituído pela cúpula dos três poderes, (b) um corpo de funcionários, e (c) uma força militar e policial.

O aparelho do Estado é regido basicamente pelo direito constitucional e pelo direito administrativo, enquanto que o Estado é fonte ou sancionador e garantidor desses e de todos os demais direitos. Quando somamos ao aparelho do Estado todo o sistema institucional-legal, que regula não apenas o próprio aparelho do Estado mas toda a sociedade, temos o Estado.

5.1 Os Setores do Estado

No Aparelho do Estado é possível distinguir quatro setores:

NÚCLEO ESTRATÉGICO. Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É portanto o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e, no poder executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas.

ATIVIDADES EXCLUSIVAS. É o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado - o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplos temos: a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes, etc.

SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado.

Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da saúde, ou porque possuem “economias externas” relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus.

PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O MERCADO.

Corresponde à área de atuação das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de infra-estrutura. Estão no Estado seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, tornando-se necessário no caso de privatização, a regulamentação rígida.

5.2 Setores do Estado e Tipos de Gestão

Cada um destes quatro setores referidos apresenta características peculiares, tanto no que se refere às suas prioridades, quanto aos princípios administrativos adotados.

No núcleo estratégico, o fundamental é que as decisões sejam as melhores, e, em seguida, que sejam efetivamente cumpridas. A efetividade é mais importante que a eficiência. O que importa saber é, primeiro, se as decisões que estão sendo tomadas pelo governo atendem eficazmente ao interesse nacional, se correspondem aos objetivos mais gerais aos quais a sociedade brasileira está voltada ou não. Segundo, se, uma vez tomadas as decisões, estas são de fato cumpridas.

Já no campo das atividades exclusivas de Estado, dos serviços não-exclusivos e da produção de bens e serviços o critério eficiência torna-se fundamental. O que importa é atender milhões de cidadãos com boa qualidade a um custo baixo.

Como já vimos, existem ainda hoje duas formas de administração pública relevantes: a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA e a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL. A primeira, embora sofrendo do excesso de formalismo e da ênfase no controle dos processos, tem como vantagens a segurança e a efetividade das decisões. Já a administração pública gerencial caracteriza-se fundamentalmente pela

eficiência dos serviços prestados a milhares senão milhões de cidadãos. Nestes termos, no núcleo estratégico, em que o essencial é a correção das decisões tomadas e o princípio administrativo fundamental é o da efetividade, entendido como a capacidade de ver obedecidas e implementadas com segurança as decisões tomadas, é mais adequado que haja um misto de administração pública burocrática e gerencial.

No setor das atividades exclusivas e de serviços competitivos ou não exclusivos, o importante é a qualidade e o custo dos serviços prestados aos cidadãos. O princípio correspondente é o da eficiência, ou seja, a busca de uma relação ótima entre qualidade e custo dos serviços colocados à disposição do público. Logo, a administração deve ser necessariamente gerencial. O mesmo se diga, obviamente, do setor das empresas, que, enquanto estiverem com o Estado, deverão obedecer aos princípios gerenciais de administração.

5.3 Setores do Estado e Formas de Propriedade

Outra distinção importante é a relacionada às formas de propriedade. Ainda que vulgarmente se considerem apenas duas formas, a PROPRIEDADE ESTATAL e a PROPRIEDADE PRIVADA, existe no capitalismo contemporâneo uma terceira forma, intermediária, extremamente relevante: a PROPRIEDADE PÚBLICA NÃO-ESTATAL, constituída pelas organizações sem fins lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente para o atendimento do interesse público. O tipo de propriedade mais indicado variará de acordo com o setor do aparelho do Estado.

No núcleo estratégico a propriedade tem que ser necessariamente estatal. Nas atividades exclusivas de Estado, onde o poder extroverso de Estado é exercido, a propriedade também só pode ser estatal.

Já para o setor não-exclusivo ou competitivo do Estado a propriedade ideal é a pública não-estatal. Não é a propriedade estatal porque aí não se exerce o poder de Estado. Não é, por outro lado, a propriedade privada, porque se trata de um tipo de serviço por definição subsidiado. A propriedade pública não-estatal torna mais fácil e direto o controle social, através da participação nos conselhos de administração dos diversos segmentos envolvidos, ao mesmo tempo que favorece a parceria entre sociedade e Estado. As organizações nesse setor gozam de uma autonomia administrativa muito maior do que aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em compensação seus dirigentes são chamados a

assumir uma responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade, na gestão da instituição.

No setor de produção de bens e serviços para o mercado a eficiência é também o princípio administrativo básico e a administração gerencial, a mais indicada. Em termos de propriedade, dada a possibilidade de coordenação via mercado, a propriedade privada é a regra. A propriedade estatal só se justifica quando não existem capitais privados disponíveis - o que não é mais o caso no Brasil - ou então quando existe um monopólio natural. Mesmo neste caso, entretanto, a gestão privada tenderá a ser a mais adequada, desde que acompanhada por um seguro sistema de regulação.

6 Objetivos

A definição dos objetivos e estratégias da reforma do aparelho do Estado apresentada a seguir decorre do diagnóstico e dos pressupostos teóricos que presidiram a análise anterior.

Dada a crise do Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do Estado mínimo, é necessário reconstruir o Estado, de forma que ele não apenas garanta a propriedade e os contratos, mas também exerça seu papel complementar ao mercado na coordenação da economia e na busca da redução das desigualdades sociais.

Reformar o Estado significa melhorar não apenas a organização e o pessoal do Estado, mas também suas finanças e todo o seu sistema institucional-legal, de forma a permitir que o mesmo tenha uma relação harmoniosa e positiva com a sociedade civil.

A reforma do Estado permitirá que seu núcleo estratégico tome decisões mais corretas e efetivas, e que seus serviços - tanto os exclusivos, que funcionam diretamente sob seu comando, quanto os competitivos, que estarão apenas indiretamente subordinados na medida que se transformem em organizações públicas não-estatais - operem muito mais eficientemente.

Reformar o aparelho do Estado significa garantir a esse aparelho maior governança, ou seja, maior capacidade de governar, maior condição de implementar as leis e políticas públicas. Significa tornar muito mais eficientes as atividades exclusivas de Estado, através da transformação das autarquias em “agências autônomas”, e tornar também muito mais